2026年税务师《涉税服务相关法律》三色笔记

第一章　行政法总论

【知识点】行政法的基本原则

（一）**行政合法性原则（形式合法性原则）**

（1）行政权力的**存在有法律依据**；

（2）行政权力必须**按照法定程序行使**。

【示例】税务机关征税既要符合实体法（如,所得税法）的规定，又要符合程序法（如,税收征管法）的规定。

【解释】行政合法性原则讲的是无法律无行政的问题，即法无授权即禁止。公民权叫法无禁止即自由。

（二）**行政合理性原则**（**实质合法**：行政裁量权的体现）

1.行政行为应**符合立法宗旨及意图，目的**。

【示例】城管不能追着“小贩”满街跑。

2.行政行为应建立在**考虑相关因素**的基础上。

3.平等地适用法律规范，遵循行政惯例或先例，做到相同情况相同对待，不同情况区别对待。

4.行政行为应保持**适度**、**符合比例原则**要求。

【示例】政府不能用“大炮”打“蚊子”。

5.行政行为应符合法理、情理及事理要求，符合自然规律、客观性要求和社会道德观念，符合人类理性和公平正义观念。

（三）**行政应急性原则**（**合法性例外**），行使条件：

1.存在**明确无误的紧急危险或者危害**；

2.非法定机关不得行使应急权力，否则无效，事后追认除外；

3.行政机关作出应急行为应接受有权（权力）机关的监督；

4.行政机关行使应急权力时，应当尊重和保障人权，应当遵循合目的原则、比例原则以及安全原则。

【解释】遵循比例原则主要是要求行政应急行为应当适当、适度，尽最大可能将负面损害控制在最小或者最低程度的范围内。

【知识点】中央行政机关

国务院	行政主体：**制定行政法规**	最高国家行政机关，管理全国性行政事务
国务院组成部门	行政主体：**制定规章**、事务管理及裁决争议	如：**财政部、中国人民银行、审计署、**自然资源部、农业农村部、国家卫生健康委员会、科学技术部等
国务院直属特设机构	行政主体	如：**国有资产监督管理委员会**
国务院直属机构	行政主体：**制定规章**、处理行政事项、裁决争议	如：**中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、海关总署、**国家统计局、国家医疗保障局、国家金融监督管理总局、国家知识产权局、国家信访局等
国务院办事机构	**不是行政主体**	如：国务院研究室

国务院直属事业单位	一般不是行政主体，**经过授权后具有行政主体资格**	如：新华通讯社、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院、国务院发展研究中心、中央广播电视总台、中国气象局等
国务院部委、总局管理的国家局	行政主体	如：中国人民银行管理的国家外汇管理局、应急管理部管理的国家矿山安全监察局、国家发展和改革委员会管理的国家数据局等

【知识点】行政行为的分类

分类标准	内容
以适用与效力作用的对象范围为标准	**内部行政行为，对内**，如针对公务员的行政处分
	外部行政行为，对外，如行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收等
以对象是否特定为标准	**抽象行政行为**，即制定规范性文件，**对象不特定不具体**
	具体行政行为，对象特定具体，如行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收等
以受法律规范拘束的程度为标准	**羁束行政行为**，如税务局征税
	裁量行政行为，如税务局罚款
以行政主体是否可以主动作出行政行为为标准	**依职权的行政行为**，如行政征收、行政处罚、行政强制、税务局征税
	依申请的行政行为，如行政许可、行政复议
以行政行为成立时参与意思表示的当事人数目为标准	**单方行政行为**，如行政处罚、行政许可等
	双方行政行为，如行政协议，代表为投资协议
以行政行为是否应当具备一定的法定形式为标准	**要式行政行为**，绝大多数行政行为 如税务机关作出行政复议决定应当以《行政复议决定书》的形式作出，并加盖该税务机关印章，不得以《行政复议事项告知书》等方式作出或者代替
	非要式行政行为，如公安机关对醉酒的人采取强制约束的行为
以行政行为是否以作为方式表现为标准	**作为行政行为**，如行政处罚、行政许可、行政奖励、行政强制行为等
	不作为行政行为，如公安局不履行保护人身权、财产权的法定职责
以行政行为的内容对行政相对人是否有利为标准	**授益性行政行为**，如行政许可、行政奖励、行政给付、税务局确认或决定减税免税
	损益性行政行为，如行政处罚、行政征收等
以行政权作用的表现方式和实施行政行为所形成的法律关系为标准	**行政立法行为**，如制定行政法规和行政规章
	行政执法行为，如行政许可、行政确认、行政奖励、行政处罚、行政强制、行政监督检查等

	行政司法行为（“准”司法），如行政调解、行政裁决、行政仲裁、行政复议等 【注】行政诉讼不属于行政司法，而是真正的司法行为	
行政终局裁决行为	“法律”规定由行政机关最终裁决的行政行为	均不可打行政诉讼
国家行为	涉及国家重大利益，具有高度政治性的行为，如国防、外交，如果行政相对人因此遭受损失，可申请国家补偿。	

第二章　行政许可法律制度

【知识点】行政许可设定权划分

法律渊源	设定权限
法律 —经常性许可	是确定行政许可的主要依据，以下**只能由法律予以设定**： （1）**国家基本制度**，如采矿许可、草原使用许可、伐木许可等 （2）**公民基本权利**，如公民健康权、环境权、劳动权的许可制度
行政法规 —经常性许可	尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可； 注：**必要时**，国务院可以采用发布决定的方式设定**临时性行政许可**，如有关网约车的许可来自于 2004 年国务院的决定，但此决定属于规章以下的规范性文件，不是行政法规

法律渊源	设定权限	备注
地方性法规—经常性许可	尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可	（1）不得设定应当由**国家统一确定的公民、法人或其他组织的资格、资质的许可**； （2）不得设定**企业或其他组织的设立登记及其前置性许可**（如取得《食品卫生许可证》后才能办理《营业执照》）。 （3）其设定的行政许可，不得**限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场**
省级地方政府规章—临时性许可	省、自治区、直辖市政府规章可以设定临时性的行政许可	
其他规范性文件	**包括部门规章，不得设定行政许可**	
目前我国税务行政许可事项仅保留增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批。		

【知识点】行政许可实施程序

（一）行政许可实施的审查与决定程序

审查方式	（1）书面审查：材料齐全、符合形式，能够当场决定的当场决定（**形式审查看材料**） （2）实质审查：对申请材料的实质内容，就其真实性、合法性进行书面审查。也可以进行**实地核查**，但是应当指派**两名以上工作人员**进行 （3）直接关系他人重大利益：事先告知利害关系人，听取申请人、利害关系人的意见
决定方式	（1）符合条件：许可证件（如需要就颁发），公众有权查阅（行政公开）。检验、检测、检疫，可以在物品上加标签或加印章 （2）不符合条件：书面不许可决定，**说明理由**（不利决定说明理由）

（二）行政许可听证程序

1. 启动方式：

主动举行	（1）法律、法规、规章规定应当听证的事项 （2）行政机关认为需要听证的**涉及公共利益的重大行政许可**事项

申请举行	直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的

2. 期限：行政机关在收到听证申请后 20 日内组织听证。

（三）行政许可的变更与延续

1. 变更：随时提出要求。

2. 延续：在有效期届满**“30 日前”**提出申请，法律、法规、规章另有规定的除外。行政机关在有效期届满前决定，**逾期的视为准予延续（默视批准）**。

【解释】默视批准只适用于延续申请，**不适用于初次申请许可和变更许可。**

（四）税务行政许可实施程序

1. 公示、申请与受理

公示	（1）八项公示：事项、依据、条件、数量、程序、期限、需提交全部材料目录、申请书示范文本和服务指南等 【注意】行政机关提供行政许可申请书格式文本，**不得收费**。 （2）公示场所：在办税服务厅或者其他办公场所以及税务机关门户网站予以公示
申请	（1）可以自行或委托代理人申请。 （2）可以通过信函和电子或网上办理平台等方式提交申请书（书面）。 （3）税务行政许可实施机关与申请人不在同一县（市、区、旗）的，申请人可选择由其主管税务机关代为转报申请材料。 【注意】代转报一般应当在**“5 工作日内”**完成。 （4）有条件的税务机关可以通过信息化手段现申请料网上传递
受理	（1）不需要取得税务许可：即时告知不受理。 （2）不属本税务机关职权：即时书面决定不予受理，告知正确机关。 （3）材料存在可以当场更正的错误：**应当允许当场更正**。 （4）材料不齐全或不符合法定形式：**当场或 5 日内一次告知补正**内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。 （5）各项符合：应当书面决定受理

【提示】税务行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。

2. 审查与决定

审查方式	书面审查为原则；根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行**实地核实的，应当指派两名以上税务人员进行核查**
决定方式	（1）当场决定 （2）不能当场决定的：20 日内决定 → 本机关负责人批准延长 10 日（延长理由告知申请人），法律、法规另有规定的除外 （3）存在争议的或者重大的税务行政许可事项：应当进行合法性审查，并经集体讨论决定 （4）准予许可，决定之日起 **7 日内公开** （5）不予许可，应当制作《不予税务行政许可决定书》，并应当说明理由，告知复议

	或行政诉讼的权利 （6）准予税务行政许可决定只在作出决定的税务机关管辖范围内有效

3. 听证

（1）启动方式：

主动举行	①法律、法规规定实施税务许可应当听证的事项； ②税务行政机关认为需要听证的**涉及公共利益的重大行政许可**事项
申请举行	直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的

（2）期限

申请期限	被告知听证权利之日起 **5 日内**提出申请
告知期限	税务行政机关在举行听证 **7 日前公告**通知申请人或利害关系人听证时间、地点，必要时予以公告

（3）程序

形式	**除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的外，应当公开**
回避	审查税务许可申请的工作人员不得担任听证主持人
质证	申请人、利害关系人可以提出证据，并进行申辩和质证
收费	**免费**
案卷排他	税务行政机关**应当根据听证笔录，作出行政许可决定**

【知识点】行政许可的撤回、撤销和注销

（一）行政许可的变更撤回

可变更撤回	行政许可所依据的法律、法规、规章**修改或者废止**，或者准予行政许可所依据的**客观情况发生重大变化**的，**为了公共利益的需要**，行政机关可以依法**变更或者撤回**已经生效的行政许可。
有损失应补偿	由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当依法给予**补偿**。

（二）行政许可的撤销

可以撤销 规律：一般贬义词（官员错）	（1）工作人员**滥用职权、玩忽职守**作出准予行政许可决定； （2）**超越法定职权**作出准予行政许可决定的； （3）**违反法定程序**作出准予行政许可决定的； （4）对不具备申请资格或不符合法定条件的申请人准予行政许可的； （5）依法可以撤销行政许可的其他情形。
应当撤销 规律：骗贿（百姓错）	相对人以**欺骗或贿赂等不正当手段**取得行政许可
【注】撤销可能对公共利益造成重大损失时，不得撤销	

（三）行政许可的注销

规律：客观原因

到期了	行政许可有效期届满未延续的；
人死丧	赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的；如律师死亡，其资质子女不能继承，只能注销
组织死	法人或者其他组织依法终止的；
撤吊	行政许可依法被撤销、撤回，或许可证件依法被吊销的；
不可抗	不可抗力导致行政许可事项无法实施的；
兜底	法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形

【注】撤销指该许可实施时即违法、有瑕疵；注销只是手续的办理问题，该许可可能有瑕疵。

第三章　行政处罚法律制度

【知识点】行政处罚的种类和设定

（一）行政处罚的种类★★★

1.行政处罚的法定种类

行政处罚法规定的行政处罚种类	税务行政处罚的主要种类
（1）警告、通报批评 （2）罚款、没收违法所得、没收非法财物 （3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 （4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 （5）行政拘留 （6）法律、行政法规规定的其他行政处罚	（1）罚款 （2）没收违法所得 （3）停止出口退税权 （4）吊销税务行政许可证件 **（口诀：停掉罚没）**

【注意 1】加处罚款或滞纳金属于行政强制执行；征收国有土地上的房屋属于行政征收。

【注意 2】不属于税务行政处罚的情形：

（1）属于行政处罚：如，警告、行政拘留、暂扣许可证件。

（2）属于行政命令，属于纠正违法行为本身的一种措施，不具有制裁性：责令限期改正（包括责令停止税收违法行为、责令改正税收违法行为、责令限期进行纳税调整等）。

（3）属于间接强制执行措施：收缴或者停售发票。

（4）税务具体管理行为：通知有关部门阻止出境、取消一般纳税人资格、收缴税务登记证、停止抵扣等。

2.行政处罚的理论分类

理论分类	法定分类
精神罚	（1）警告、通报批评
财产罚	（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物
行为罚	（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件
	（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业
人身自由罚	（5）行政拘留

【注意 1】行政拘留与刑事拘留性质不同，**行政拘留属于行政处罚，刑事拘留属于刑事强制措施。**

【注意 2】注意区分行政处罚中的没收违法所得与刑罚种类中的没收财产。

（二）行政处罚的设定★★

项目	创设权	具体规定权
法律	n	**上位法有设定的，下位法不得再设定，但是下位法可以在上位法设定的范围内作出具体规定**
行政法规	n-限制人身自由	
地方性法规	n-限制人身自由-吊销营业执照	
部门规章	警告、通报批评、一定数额罚款（国务院规定上限）	

地方规章	警告、通报批评、一定数额罚款（省级人大常委会规定上限）	

【注】“n”指的是所有的行政处罚。

【知识点】行政处罚的管辖与适用

（一）行政处罚的管辖

类别	内容
地域管辖	原则上由**违法行为发生地的行政机关**管辖。 【注意】法律、行政法规、部门规章另有规定的，从其规定。海关行政处罚实施条例规定，海关行政处罚由发现违法行为的海关管辖，也可以由违法行为发生地海关管辖
级别管辖	原则上由**县级以上**具有行政处罚权的行政机关管辖，法律、行政法规另有规定的除外 省、自治区、直辖市根据当地实际情况，可以决定将基层管理迫切需要的县级政府部门的行政处罚权交由能够有效承接的乡镇人民政府、街道办事处行使，并定期组织评估，决定应当公布
共同管辖	两个以上行政机关都有管辖权的，由**最先立案**的行政机关管辖
指定管辖	管辖发生争议的，应当**协商**解决，协商不成的，报请**共同的上一级**行政机关指定管辖； 也可以直接由**共同的上一级行政机关指定**管辖
协助管辖	行政机关因实施行政处罚的需要，可以向有关机关提出协助请求 【注意】协助事项属于被请求机关职权范围内的，应当依法予以协助
移送管辖	违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任 【注意】对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚，但应当给予行政处罚的，司法机关应当及时将案件移送有关行政机关

（二）行政处罚的适用

1.行政处罚的适用情形

责令改正	行政机关实施行政处罚时，**应当**责令当事人改正或者限期改正违法行为
退赔没收	当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收
从旧兼从轻	实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定 【注意】但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定
行政刑事处罚对接	（1）违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期 （2）违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金； 行政机关尚未给予当事人罚款的，不再给予罚款

2.行政处罚的适用方式

应当不予处罚	**应当从轻、减轻**处罚

（1）**不满 14 周岁**的未成年人有违法行为的 （2）精神病人、智力残疾人在**不能辨认或者不能控制自己行为时**有违法行为的 （3）违法行为轻微并及时纠正，**没有造成危害后果**的 （4）违法行为在 2 年内未被发现的；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，该期限延长至 5 年。但是法律另有规定的除外 （5）当事人有证据足以证明**没有主观过错的**，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定 【注意】初次违法且危害后果轻微并及时改正的，**可以不予**行政处罚 【提示】对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育	（1）**已满 14 周岁不满 18 周岁**的未成年人有违法行为的 （2）**主动消除或减轻**违法行为危害后果的 （3）受他人**胁迫**或者**诱骗**有违法行为的 （4）**主动供述**行政机关**尚未掌握**的违法行为的 （5）配合行政机关查处违法行为有立功表现的 【注意】尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，**可以从轻或者减轻**行政处罚

【提示】（1）发生重大传染病疫情等突发事件，为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，行政机关对违反突发事件应对措施的行为，**依法快速、从重处罚**。

（2）对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

（三）行政处罚的追究时效

1. 追究时效的起点：从违**法行为发生之日**起计算；

违法行为有连续或者继续状态的，从**行为终了之日**起计算。

2. 追究时效的长度

项目	内容
行政处罚法	违法行为在 **2 年内**未被发现的，不再给予行政处罚 涉及公民**生命健康安全、金融安全且有危害后果**的，上述期限延长至 **5 年** 法律另有规定的除外
税收征管法	在 **5 年内**未被发现的，不再给予行政处罚
治安管理处罚法	违反治安管理行为在 **6 个月内**没有被公安机关发现的，不再处罚

【知识点】行政处罚听证程序

1.以当事人**申请为前提**；

2.组织听证是一定条件下行政处罚实施机关的法定程序义务。

	行政处罚	税务行政处罚
听证的范围（**超级歌诀：罚没责吊罚没**）	（1）较大数额罚款； （2）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物； （3）责令停产停业、责令关闭、限制	（1）罚款**【公民 2000 元以上（含本数）、组织 10000 元以上（含本数）】**； （2）没收较大数额违法所得 （3）吊销税务行政许可证件规律：罚

吊）	从业； （4）吊销许可证件、降低资质等级； （5）其他较重的行政处罚； （6）法律、法规、规章规定的其他情形。 **规律：罚款、没收、责令、吊销（比行政处罚全部种类少了警报、暂扣、拘留）**	款、没收、吊销**（比一般行政处罚的听证少了责令）**
提出与通知	（1）当事人要求听证的，应当在行政机关告知后 **5 日内**提出，申请形式未明确规定 （2）举行期限未明确规定 （3）行政机关应当在举行听证的 7 日前将相关事项通知当事人	（1）要求听证的当事人，应当在《税务行政处罚事项告知书》送达后 5 日内向税务机关书面提出听证；**逾期不提出的，视为放弃听证权利** （2）行政机关收到听证要求后 **15 日内举行**听证 （3）行政机关在举行听证的 7 日前将《税务行政处罚听证通知书》送达当事人
公开举行	**除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，听证公开举行**	
主持人与当事人	（1）非本案调查人员主持 （2）当事人可以亲自参加，也可**委托 1-2 人代理**参加听证	
听证权利的放弃	当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听证的，视为放弃听证权利，行政机关终止听证	
笔录	（1）**听证应当制作听证笔录；** （2）笔录应当交当事人或者其代理人核对无误后签字或者盖章。 （3）当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在笔录中注明（案卷制度）	（1）听证的全部活动，应当由记录员写成笔录，经听证主持人审阅并由听证主持人和记录员签名后，封卷上交税务机关负责人审阅 （2）听证笔录应交当事人或者其代理人、本案调查人员、证人及其他有关人员阅读或者向他们宣读，他们认为有遗漏或者有差错的，可以请求补充或者改正。他们在承认没有错误后，应当签字或者盖章。 （3）拒绝签字或者盖章的，记明情况附卷

第四章　行政强制法律制度

【知识点】行政强制的种类

行政强制措施	行政强制执行
（1）限制公民人身自由（如强制扣留，强制搜查，强制治疗，现场管制，强行驱散） （2）查封场所、设施或者财物； （3）扣押财物； （4）冻结存款、汇款； （5）其他，如强制进入场所、证据先行登记保存、交通管制、通信管制等	（1）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物； （2）排除妨碍、恢复原状； （3）代履行； （4）加处罚款或者滞纳金； （5）划拨存款、汇款； （6）其他，如强制履行兵役、强制收购、强制教育等

【知识点】查封、扣押★★★

1.实施主体：法律、法规规定的行政机关实施。

【提示】《税收征收管理法》38 条规定，税务机关依法享有扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产的权利。

2.范围

（1）查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物，**不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物**；

（2）不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的**生活必需品**；

（3）当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，**不得重复查封**。

3.程序

（1）行政机关决定实施查封、扣押的，应当依照法定程序进行，制作并**“当场”**交付查封、扣押决定书和清单。

（2）查封、扣押决定书应当载明下列事项：

①当事人的姓名或者名称、地址；

②查封、扣押的理由、依据和期限；

③查封、扣押场所、设施或者财物的名称、数量等；

④申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

⑤行政机关的名称、印章和日期。

4.时限

（1）查封、扣押的期限**不得超过 30 日**；

情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过 30 日；法律、行政法规另有规定的除外。

【提示】税务机关采取税收保全措施的期限**一般不得超过 6 个月**；重大案件需要延长的，应当报**国家税务总局**批准。

（2）对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间。检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间应当明确，并书面告知当事人。

（3）检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用**“由行政机关承担”**。

5.保管和赔偿

（1）对查封、扣押的场所、设施或者财物，**行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；因未尽妥善保管义务造成损失的，应当承担赔偿责任。**

（2）对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。

【提示】因第三人的原因造成的损失，行政机关**“先行赔付”**后，有权**向第三人追偿**。

（3）因查封、扣押发生的保管费用**“由行政机关承担”**。

6.解除

（1）行政机关应当及时作出解除查封、扣押决定的情形：

①当事人没有违法行为；

②查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关；

③行政机关对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；

④查封、扣押期限已经届满。

（2）解除查封、扣押应当立即退还财物；已将鲜活物品或者其他不易保管的财物拍卖或者变卖的，退还拍卖或者变卖所得款项。变卖价格明显低于市场价格，给当事人造成损失的，应当**给予补偿**。

【知识点】行政强制执行实施的一般规定

（一）实施主体

（1）具有行政强制执行权的行政机关。

（2）法律、行政法规授权的具有管理公共事务职能的组织。

（二）程序

1.催告

催告是强制执行决定的前置程序。行政机关作出强制执行决定前，应当**事先催告**当事人履行义务。

【注意】立即代履行中没有催告程序。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：

（1）履行义务的**期限**。

（2）履行义务的**方式**。

（3）涉及金钱给付的，应当有**明确的金额和给付方式**。

（4）当事人依法享有的**陈述权和申辩权**。

2.当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。

3.听取意见：行政机关**应当充分听取**当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录、复核。

当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。

4.当事人的行为导致不同的法律后果

（1）经催告，当事人履行行政决定的，不再实施强制执行。

（2）经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出强制执行决定。

（3）在催告期间，**对有证据证明有转移或者隐匿财物迹象的，行政机关可以作出立即强制执行决定。**

【注意】强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：当事人的姓名或名称、地址；强制执行的理由和依据；强制执行的方式和时间；**申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；**行政机关的名

称、印章和日期。

（三）特殊规定

1.文明执法

（1）行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。

【注意】紧急情况包括有证据证明有转移或者隐匿财物迹象的，以及需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物而当事人不能清除的情形。

（2）行政机关**不得对居民生活**采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。

2.中止执行与终结执行

中止执行	终结执行
（1）当事人履行行政决定**确有困难**或者暂无履行能力的 （2）第三人对执行标的主张权利，**确有理由**的 （3）执行可能造成难以弥补的损失，且中止执行**不损害公共利益**的 【注意】该规定体现了比例原则的要求，即应采取损害最小的方式实现行政管理目的	（1）公民死亡，**无遗产可供执行，又无义务承受人**的 （2）法人或者其他组织终止，**无财产可供执行，又无义务承受人的** （3）执行标的**灭失**的 （4）据以执行的行政决定**被撤销**的
（4）行政机关认为需要中止执行的其他情形。 中止执行的情形消失后，行政机关应当恢复执行。 对没有明显社会危害，当事人确无能力履行，中止执行满 3 年未恢复执行的，行政机关不再执行	（5）行政机关认为需要终结执行的其他情形 【注意】实践中，税务稽查案件终结执行后，如发现被执行人又有财产可执行的，税务局稽查局依照职权恢复执行
在执行中或者执行完毕后，据以执行的行政决定被撤销、变更，或者执行错误的，应当恢复原状或者退还财物；不能恢复原状或者退还财物的，依法给予赔偿	

3.执行协议

实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议。

执行协议可以约定分阶段履行；当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚款或者滞纳金。

【注意】在强制执行阶段，**罚款本金、税款本金、行政性收费本金不适用执行和解的减免规定。**

执行协议应当履行，当事人不履行执行协议的，行政机关应当恢复强制执行。

【知识点】申请法院强制执行

申请	申请条件： 当事人**在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，**没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起 **3 个月内**，申请法院强制执行
	催告： **行政机关申请法院强制执行前，应当催告当事人履行义务**。催告书送达 **10 日后**当事人仍未履行义务的，行政机关可以向所在地有管辖权的法院申请强制执行。

	执行对象是不动产的，向不动产所在地有管辖权的法院申请强制执行。 基层人民法院认为执行确有困难的，可以报请上级人民法院执行；上级人民法院可以决定由其执行，也可以决定由下级人民法院执行
	申请材料： ①强制执行申请书； ②行政决定书及作出决定的事实、理由和依据； ③当事人的意见和行政机关催告情况； ④申请强制执行标的情况； ⑤法律、行政法规规定的其他材料。 强制执行申请书应当由行政机关负责人签名，加盖行政机关的印章，并注明日期。
受理	法院接到申请，在 5 日内受理
	不予受理：15 日+15 日 若行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在 15 日内向上一级法院申请复议，上一级法院应当自收到复议申请之日起 15 日内作出是否受理的裁定
审查	对符合法律规定，且行政决定具备法定执行效力的，法院自受理之日起 7 日内作出执行裁定
	因情况紧急，为保障公共安全，行政机关可以申请法院立即执行，经法院院长批准，法院自作出执行裁定之日起 5 日内执行
执行费用	（1）**行政机关申请法院强制执行，不缴纳申请费。强制执行的费用由被执行人承担。** （2）法院以划拨、拍卖方式强制执行的，可以在划拨、拍卖后将强制执行的费用扣除。 规律：执行费坏人担
	【提示】行政强制措施的费用 （1）查封、扣押的标的物的检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用由行政机关承担。 （2）因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。

第五章　行政复议法律制度

【知识点】行政复议管辖

1. 县级以上地方各级政府的复议管辖范围

本级政府管辖	对本级政府**工作部门**作出的行政行为不服的
	对下**一级政府**作出的行政行为不服的
	对本级政府依法设立的**派出机关**（如街道办）作出的行政行为不服的
	对本级政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章**授权的组织**作出的行政行为不服的
	省、自治区政府依法设立的派出机关（如阿里地区行政公署）参照设区的市级政府的职责权限，管辖相关行政复议案件
	对县级以上地方各级政府工作部门依法设立的**派出机构**（如派出所、税务所、财政所）依照法律、法规、规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的行政复议案件，由本级政府管辖 【注】本级政府或所在地政府管辖：**对直辖市、设区的市政府工作部门按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其所在地的政府管辖**
本机关管辖	**省、自治区、直辖市政府同时管辖对本机关作出的行政行为不服的行政复议案件**
	对此行政复议决定不服，可以向法院提起诉讼，或向**国务院申请最终裁决**

2. 国务院部门复议管辖范围

本机关管辖	对**本部门**作出的行政行为不服的，对此行政复议决定不服，可以向法院提起诉讼，或向国务院申请最终裁决
上级管辖	对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的，如国家金融监督管理总局在 31 个省、自治区、直辖市和 5 个计划单列市设立 36 个监管局
	对本部门管辖的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服的

3. 对垂直领导机关、税务和国家安全机关行政行为不服的复议管辖

垂直管辖	对**海关、金融、外汇管理、税务和国安**的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。 **口诀：海外金税安**

4. 对司法行政部门行政行为不服的复议管辖

选择管辖	对履行行政复议职责的地方政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向本级政府或上一级司法行政部门申请行政复议。 如睢县司法局对没有取得律师职业证书的老刘以律师名义从事法律服务业务，责令停止非法执业，没收违法所得 1 万元，罚款 1 万元。

【知识点】行政复议的实施程序

1. 申请期限

（1）提出复议申请的期限

一般复议期限：①公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 **60 日内**提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限**超过 60 日的除外。**因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。②行政机关作出行政行为时，**未告知**公民、法人或者其他组织**申请行政复议的权利**、行政复议机关和**申请期限**的，申请期限自公民、法人或者其他组织**知道或者应当知道**申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限**之日起计算**，但是自知道或者应当知道行政行为内容之日起**最长不得超过 1 年**。

特殊复议期限：只有法律规定超过 60 日的才有效。
（2）复议期限的起算
①当场作出行政行为：作出之日
②载明行政行为的法律文书直接送达受送达人：签收之日
③载明行政行为的法律文书邮寄送达：邮件签收单上签收之日；没有邮件签收单的，自受送达人在送达回执上签名之日
④依法通过公告形式告知受送达人：公告规定的期限届满之日
⑤作出行政行为时未告知公民、法人或者其他组织，事后补充告知的：该公民、法人或者其他组织收到行政机关补充告知的通知之日
⑥能够证明公民、法人或者其他组织知道行政行为的：证据材料证明其知道行政行为之日
⑦不履行法定职责：有履行期限，履行期限届满之日。没有履行期限，行政机关收到申请满 60 日的。
在紧急情况下请求行政机关履行保护人身权、财产权的法定行职责，行政机关不履行的，行政复议申请期限不受上述规定限制。
2. 行政复议前置。
有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：①对**当场作出的行政处罚**决定不服；②对行政机关作出的**侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权**的决定不服；③认为行政机关存在《行政复议法》第 11 条规定的**未履行法定职责**情形；④**申请政府信息公开，行政机关不予公开**；⑤法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。
3. 行政复议普通程序
（1）听取意见。行政复议机构**应当当面或者通过互联网、电话等方式听取当事人的意见**，并将听取的意见记录在案。因当事人原因不能听取意见的，**可以书面审理。**
（2）行政复议听证程序。

适用范围	审理**重大、疑难、复杂**的行政复议案件，行政复议机构**应当组织**听证。行政复**议机构认为有必要**听证，或者**申请人请求听证**的，行政复议机构**可以组织听证**
听证主持人与听证员	听证由 1 名行政复议人员任**主持人，2 名以上**行政复议人员任**听证员**，1 名记录员制作听证笔录
听证通知	行政复议机构组织听证的，应当于举行听证的 **5 日前**将听证的时间、地点和拟听证事项书面通知当事人
申请人参加听证	申请人无正当理由拒不参加听证的，视为放弃听证权利
被申请人参加听证	**被申请人的负责人应当参加听证。不**能参加的，应当说明理由并委托相应的工作人员参加听证

4. 行政复议简易程序
行政复议机关审理下列行政复议案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：
（1）被申请行政复议的行政行为是**当场作出**。
（2）被申请行政复议的行政行为是**警告或者通报批评**。
（3）案件涉及款额 **3000 元以下**。
(4) 属于**政府信息公开**案件。
除前述规定以外的行政复议案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序。
【知识点】行政复议决定

<table>
<tr><td>种类</td><td colspan="2">适用情形</td></tr>
<tr><td>（1）维持决定</td><td colspan="2">事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当</td></tr>
<tr><td>（2）履行决定</td><td colspan="2">针对不作为：被申请人没有履行法定职责，且履行还有意义，决定其在一定期限内履行</td></tr>
<tr><td>（3）变更决定</td><td colspan="2">a.事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，但是内容不适当
b.事实清楚，证据确凿，程序合法，但是未正确适用依据
c.事实不清、证据不足，经行政复议机关查清事实和证据
行政复议机关不得作出对申请人更为不利的变更决定，但是第三人提出相反请求的除外</td></tr>
<tr><td>（4）撤销决定</td><td>行政行为有下列情形之一的，行政复议机关决定撤销或者部分撤销该行政行为，并可以责令被申请人在一定期限内重新作出行政行为：
a.主要事实不清、证据不足
b.违反法定程序
c.适用的依据不合法
d.超越职权或者滥用职权
行政复议机关责令被申请人重新作出行政行为的，被申请人不得以同一事实和理由作出与被申请行政复议的行政行为相同或者基本相同的行政行为，但是行政复议机关以违反法定程序为由决定撤销或者部分撤销的除外</td><td rowspan="3">被申请人不按照规定提出书面答复、提交作出行政行为的证据、依据和其他有关材料的，视为该行政行为没有证据、依据，行政复议机关决定撤销、部分撤销该行政行为，确认该行政行为违法、无效或者决定被申请人在一定期限内履行，但是行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外</td></tr>
<tr><td>（5）确认违法决定</td><td>行政行为有下列情形之一的，行政复议机关不撤销该行政行为，但是确认该行政行为违法：
a.依法应予撤销，但是撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害
b.程序轻微违法，但是对申请人权利不产生实际影响</td></tr>
<tr><td>行政行为有下列情形之一，不需要撤销或者责令履行的，行政复议机关确认该行政行为违法：
a.行政行为违法，但是不具有可撤销内容
b.被申请人改变原违法行政行为，申请人仍要求撤销或者确认该行政行为违法；
c.针对不作为：被申请人不履行或者拖延履行法定职责，责令履行没有意义</td></tr>
<tr><td>（6）确认无效决定</td><td>行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，申请人申请确认行政行为无效的</td></tr>
<tr><td>（7）驳回复议请求决定
【注】决定驳回复议请求不同于驳回复议申请。决定驳回复议申请类似于行政诉讼的</td><td colspan="2">针对不作为：申请人认为行政机关不履行，受理后发现被申请人没有相应法定职责或在受理前已经履行法定职责（无职责或已尽职责）</td></tr>
</table>

裁定驳回起诉，是针对不符合受理条件的情况			
（8）责令被申请人赔偿的决定	依申请	a.应当不予赔偿的，在作出行政复议决定时，应当同时决定驳回行政赔偿请求 b.应当给予赔偿的，作出撤销或部分撤销、变更或确认违法、无效时，应当同时作出赔偿决定	返还罚款或罚金、追缴或没收的金钱、解除冻结的存款或者汇款的，应支付银行同期存款利息
	依职权	行政复议机关在依法决定撤销或部分撤销、变更罚款，撤销或部分撤销违法集资、没收财物、征收征用、摊派费用及对财产的查封、扣押、冻结等行政行为时，应当同时责令被申请人返还财产，解除查封、扣押、冻结或赔偿相应价款	

第六章　行政诉讼法律制度

【知识点】行政诉讼与行政复议的联系

1.选择型（复议、诉讼任选一）

（1）如果选择行政复议，对行政复议决定不服的，仍可以向法院提起行政诉讼；但在法定复议期限内不得向法院提起行政诉讼。

（2）如果**直接选择了行政诉讼**，法院已经依法受理的，则**不得再申请行政复议**。

2.复议前置型（先复议，后诉讼）

（1）有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：

①对**当场作出的行政处罚决定**不服；

②对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的**自然资源的所有权或者使用权**的决定不服；

③认为行政机关存在行政复议法第 11 条规定的**未履行法定职责**情形；

④申请**政府信息公开**，行政机关不予公开；

⑤法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。

（2）《反垄断法》：对反垄断执法机构（即国家市场监督管理总局）依法作出的禁止经营者集中的决定以及附加限制性条件的决定不服的，可以先依法申请复议；对行政复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼。

（3）《税收征管法》：纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议。对行政复议决定不服的，可以依法向法院起诉。

税务行政复议规则规定：公民、法人、其他组织对税务机关的征税行为不服的，应当先向行政复议机关申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼。**征税行为，包括确认纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税、退税、抵扣税款、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点和税款征收方式等具体行政行为，征收税款、加收滞纳金，扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等。**

【知识点】行政诉讼被告

1.行政诉讼被告的特殊性

（1）**对原告的诉讼请求没有反诉权。**

（2）承担被诉行政行为合法性的举证责任。

（3）有权依法执行或者改变被诉的行政行为。

2.具体情形下被告资格的确定

（1）具体情形下被告资格的一般规定

实施主体	被告
上级行政机关批准的行政行为	**署名机关**
行政机关组建并赋予行政管理职能，但没有独立承担法律责任能力的机构以自己名义作出	组建该机构的行政机关
授权的内设机构或派出机构、其他组织，**超出**	**实施该行为的机构或组织**

授权范围	
行政机关委托的组织	委托的行政机关
被撤销或职权变更的行政机关	继续行使其职权的行政机关
	没有继续行使其职权的行政机关的，以其所属的人民政府为被告；实行垂直领导的，以**垂直领导的上一级**行政机关为被告
开发区管理机构	a.对由国务院、省级人民政府批准设立的开发区管理机构作出的行政行为不服提起诉讼的，以该开发区管理机构为被告 b.国务院、省级人民政府批准设立的开发区管理机构所属职能部门作出的行政行为的，其职能部门为被告 c.其他开发区管理机构所属职能部门作出行政行为的，开发区管理机构为被告；开发区管理机构没有行政主体资格的，设立该机构的地方人民政府为被告
村民委员会、居民委员会、高等学校等事业单位以及律师协会、注册会计师协会等行业协会依据法律、法规、规章的授权履行行政管理职责的行为	村民委员会或者居民委员会、高等学校等事业单位以及律师协会、注册会计师协会等行业协会
村民委员会、居民委员会、高等学校等事业单位以及律师协会、注册会计师协会等行业协会受行政机关委托作出的行为	委托的行政机关
市、县级人民政府确定的房屋征收部门组织实施房屋征收与补偿工作过程中作出行政行为的，或者征收实施单位受房屋征收部门委托在委托范围内从事的行为	房屋征收部门

（2）经复议的案件

项目	被告
维持原行政行为	**作出原行政行为的行政机关和复议机关为共同被告**
改变原行政行为	**复议机关**为被告
既有维持原行政行为的内容，又有改变原行政行为的内容或者不予受理申请内容的	**作出原行政行为的行政机关和复议机关为共同被告**

【注意 1】“改变原行政行为”指复议机关改变原行政行为的**处理结果**。

【注意 2】**复议机关确认原行政行为无效，属于改变原行政行为。**

复议机关确认原行政行为违法，属于改变原行政行为，**但复议机关以违反法定程序为由确认原行政行**

为违法的除外。

【注意 3】复议机关在法定期限内不作复议决定，当事人对原行政行为不服提起诉讼的，以作出原行政行为的行政机关为被告；当事人对复议机关不作为不服提起诉讼的，以复议机关为被告。

（3）行政许可案件

项目	被告
行政许可	作出行政许可决定的机关为被告
许可经上级机关批准，对批准或不批准不服一并提起诉讼	上级行政机关和作出许可决定的机关为共同被告
须经下级初步审查上报，对不予初审或不予上报不服	下级行政机关或组织为被告
统一办理行政许可的	作出具有实质影响的不利行为的机关为被告

【知识点】行政诉讼第一审程序

（一）审理前的准备

1.提交答辩状	（1）5－15－5：法院应当在立案之日起 5 日内，将起诉状副本和应诉通知书发送被告。被告应当在收到起诉状副本之日起 15 日内向法院提交作出行政行为的证据和所依据的规范性文件，并提出答辩状。法院应当在收到答辩状之日起 5 日内，将答辩状副本发送原告。 （2）被告不提出答辩状的，不影响法院审理。
2.组成合议庭（不可以审判员独任审理）	（1）法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭。 （2）合议庭的成员，应当是 3 人以上的单数。
3.审核诉讼材料，调查收集证据。	
4.确定开庭审理的时间、地点，并通知	法院应当在开庭 3 日前用传唤当事人和其他诉讼参与人：传唤当事人应当使用传票；通知证人、鉴定人、勘验人、翻译人员到庭应当使用通知书

（二）开庭审理

开庭审理	一审程序中应当一律实行开庭审理，不得进行书面审理。 【注】二审特定情况下可以采用书面审理
公开审理	（1）法院应公开审理行政案件——一般原则 （2）绝对不公开：国家秘密、个人隐私和法律另有规定 （3）相对不公开：商业秘密，当事人申请不公开，可以不公开
原则上不得调解	

【注意】人民法院对被告经传票传唤无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以将被告拒不到庭或者中途退庭的情况予以公告，并可以向监察机关或者被告的上一级行政机关提出依法给予其主要负责人或者直接责任人员处分的司法建议。

（三）判决

1.判决时间

在立案之日起“6个月内”作出一审判决。

有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准；

高级人民法院审理的一审案件需要延长的，由最高人民法院批准。

2.判决类型

项目	内容
驳回诉讼请求判决	（1）证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的 （2）原告申请被告履行法定职责或者给付义务理由不成立的
撤销判决：并可以判决被告重新作出行政行为	（1）主要证据不足（2）适用法律、法规错误 （3）违反法定程序（4）超越职权 （5）滥用职权撤销判决：并可以判决被告重新作出行政行为（6）明显不当 【注意】**人民法院对原行政行为作出判决的同时，应当对复议决定一并作出相应判决**
履行判决	被告无正当理由拒不履行或拖延履行法定职责，从而责令其在一定期限内履行的判决
（可以）变更判决	认定被告行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及款额确定、认定确有错误，运用国家审判权直接予以改变的判决 【注意】**不得加重对原告的处罚（包括加重处罚幅度或增加处罚内容），但利害关系人同为原告，且诉讼请求相反的除外**
确认违法判决	行政行为有下列情形之一的，人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为： （1）行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的 （2）行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的 行政行为有下列情形之一，不需要撤销或者判决履行的，人民法院判决确认违法： （1）行政行为违法，但不具有可撤销内容的 （2）被告改变原违法行政行为，原告仍要求确认原行政行为违法的 （3）被告不履行或者拖延履行法定职责，判决履行没有意义的
确认无效判决	行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，人民法院判决确认该行政行为无效。**“重大且明显违法”是指：** **（1）行政行为实施主体不具有行政主体资格** **（2）减损权利或者增加义务的行政行为没有法律规范依据** **（3）行政行为的内容客观上不可能实施** **（4）其他重大且明显违法的情形**

【注意】人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施；给原告造成损失

的，依法判决被告承担赔偿责任。

（四）简易程序

（1）人民法院审理下列第一审行政案件，认为**事实清楚、权利义务关系明确、争议不大**的，可以适用简易程序：

①被诉行政行为是**依法当场作出**的；

②案件涉及**款额 2000 元以下**的；

③属于**政府信息公开**案件的；

④当事人**各方同意**适用简易程序的，可以适用简易程序。

（2）适用简易程序审理的行政案件，由**审判员一人独任审理**，并应当在立案之日起 45 日内审结。

（3）适用简易程序案件的举证期限由人民法院确定，也可以由当事人协商一致并经人民法院准许，但不得超过 15 日。

（4）人民法院在审理过程中，发现案情复杂、不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。

第七章　民法总论

【知识点】民事法律事实

民事法律事实，是指能引起民事法律关系发生、变更和消灭的客观事实。

1.民事法律事实的分类

（1）自然事实，是指与人的意志无关的法律事实，包括事件和状态。

项目	内容	
事件	一时性的某种客观事实	如，人的出生、死亡，自然灾害的发生等
状态	持续性的某种客观事实	如，时间的经过、对物的占有等

（2）行为，是指人的有意识的活动。

标准	分类	概念（示例）
内容和形式是否合法	合法行为	符合法律规定、受法律确认和保护的行为，如，生效法律行为、正当防卫、紧急避险等
	违法行为	不符合法律要求或者违反法律规定的行为，如，违约行为、侵权行为等
是否以行为人的意思表示为要件	表意行为	法律行为：指**以意思表示为核心要素**，如，合同、代理
		准法律行为：指由法律直接规定民法效果的表意行为，包括**意思通知（如要约拒绝、履行催告）、观念通知（如承诺迟到通知、债权让与通知）和情感表示（如被继承人对继承人的宽恕）**
	非表意行为（**事实行为**）	**无须表示内心意思即依法发生法律效果的行为**，如，建造房屋、作品创作行为、拾得遗失物、先占、无因管理、侵权行为等

2.法律事实构成

法律事实构成，是指须同时具备方能引起某一民事法律关系发生、变更或者消灭的几个法律事实的总和。

【注意】遗嘱继承关系的发生：

有效遗嘱和遗嘱人死亡两个法律事实结合，即为引起遗嘱继承关系发生的法律事实构成。

【知识点】民事权利的分类

根据民事权利客体所体现的利益性质	人身权	人格权	生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等 【提示】**法人享有名称权、名誉权、荣誉权**
		身份权	配偶权、亲权、亲属权
	财产权	物权、准物权、债权和继承权	
	知识产权	兼具人身性和财产性，如著作权、专利权、商标权	
	成员权	股权，表决权，对业务的知悉权、执行权、监督权、盈利分配权以及团体终止时的剩余财产分配权等	
根据民事权	支配权	（1）支配权的实现，凭**权利人单方的意思**即可	

利的作用方式		（2）包括物权（所有权、用益物权、担保物权）、人身权和知识产权
	请求权	请求他人为或不为一定行为的权利。如债权、返还原物请求权
	形成权	（1）依权利人**单方意思表示，**能使既存的法律关系发生变化的权利 （2）包括承认权、同意权、选择权、**撤销权、解除权、抵销权、**终止权
	抗辩权	（1）主要是针对请求权的权利，如同时履行抗辩权 （2）效力在于**阻止请求权效力的发生**
根据民事权利实现方式	绝对权	无须借助他人协助，即可行使、实现的权利。如人格权、身份权、物权、知识产权
	相对权	须借助他人的协助，方可实现的权利。如债权
根据民事权利的效力范围	对世权	能够请求**不特定的一般人**为一定行为的权利。如物权、人身权等
	对人权	仅能请求**特定的人**为一定行为的权利。如债权
根据民事权利是否可与其主体分离	专属权	只能由权利主体享有或者行使的权利。如人格权、身份权、**居住权**
	非专属权	可以与权利主体分离的权利，可以让与和继承。如**物权、债权**
根据民事权利相互间的依存关系	主权利	不依赖其他权利而独立存在的权利，如借款合同
	从权利	以其他权利的存在为其存在前提的权利，如担保物权
根据权利相互间地位	原权	原生性权利
	救济权	原权受到侵害或有被侵害的危险时产生的救济性权利，如财产权受侵害时，可要求赔偿的权利
根据民事权利要件是否全部具备	既得权	又称完整权，是指全部法律要件齐备，权利人可以现实享有和行使的权利
	期待权	又称形成中的权利，只具备部分法律要件，须待其余要件具备时才能实际发生的权利，如附生效条件的民事行为

【知识点】自然人的民事行为能力

完全民事行为能力人	标准：**≥18 周岁/（16≤X＜18＋能以自己的劳动收入作为主要生活来源**） 行为能力：能够独立实施任何民事法律行为
限制民事行为能力人	标准：**8≤X＜18 周岁/不能完全辨认自己行为的成年人** 行为能力：**仅能实施与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为以及纯获利益的民事法律行为**
无民事行为能力人	标准：＜8 周岁/不能辨认自己行为的成年人、未成年人 行为能力：须由其法定代理人代理实施民事法律行为

【知识点】民事法律行为的效力样态

（一）完全生效民事法律行为

（1）完全生效民事法律行为可以按照意思表示的内容发生行为人预期的民法效果。

（2）民事法律行为自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

（二）尚未完全生效民事法律行为

（1）尚未完全生效民事法律行为，亦称“待生效民事法律行为”，是指存在法定或者约定的特别生效要件，而该特别生效要件尚未成就的民事法律行为。

（2）尚未完全生效的民事法律行为

项目	内容
尚未满足法定特别生效要件的民事法律行为	如，法律、行政法规规定**须办理批准等手续方能生效**的民事法律行为，**尚未办理**批准等手续
尚未满足约定特别生效要件的民事法律行为	如，**附停止条件或附始期**的民事法律行为，所附停止条件尚未成就或所附期限尚未届至

（三）可撤销民事法律行为★★★

1.定义

存在法定的重大意思表示瑕疵而可以请求法院或仲裁机构予以撤销的民事法律行为。

2.可撤销民事法律行为类型

（1）基于**重大误解**所实施的民事法律行为。

【注意】行为人对行为的性质、对方当事人或者标的物的品种、质量、规格、价格、数量等产生错误认识，按照通常理解如果不发生该错误认识，行为人就不会作出相应意思表示的，可以认定为重大误解。

（2）一方以**欺诈**手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。

（3）**第三人实施欺诈**行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，且**对方知道或者应当知道**该欺诈行为的。

（4）一方或者第三人以**胁迫**手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为。

（5）一方利用对方处于**危困状态、缺乏判断能力等情形所实施的显失公平**的民事法律行为。

（6）在行为人的意思表示存在**第三人转达错误**的情形下所实施的民事法律行为。

3.撤销权的消灭

项目	内容	
消灭情形	一般	主观标准：知道或者应当知道撤销事由之日起 **1 年内**没有行使撤销权
	重大误解	主观标准：知道或者应当知道撤销事由之日起 **90 日内**没有行使撤销权
	胁迫	**胁迫行为终止之日起 1 年内**没有行使撤销权
	放弃	当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权的
	5 年	当事人自民事法律**行为发生之日起 5 年内**没有行使撤销权的

（四）效力待定民事法律行为

1.定义

民事法律效力有待第三人以行为使之确定的民事法律行为。

2.类型

（1）无权处分。

（2）狭义无权代理。

（3）债务承担。

（4）限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的、有待其法定代理人同意或者追认的民事法律行为。

【注意】相对人（不论是否善意）可以**催告**法定代理人自收到通知之日起 30 日内予以追认。法定代理人**未作表示的，视为拒绝追认**。民事法律行为被追认前，**善意相对人有撤销的权利**。撤销应当以通知的方式作出。

（五）无效民事法律行为

1.效力

自始、确定、当然的不发生固有效力。

2.情形（有硬伤）

（1）**无民事行为能力人实施**的民事法律行为。

（2）行为人与相对人**恶意串通**，损害他人合法权益的民事法律行为。

【注意】**恶意串通，是指行为人与相对人为牟取私利而相互勾结致害他人。**

（3）行为人与相对人以**虚假的意思表示实施**的民事法律行为。

【注意】行为人与相对人以虚假的意思表示所隐藏的民事法律行为有效与否，应当依据相关法律规定予以判断。

（4）**违反法律、行政法规的强制性规定**的民事法律行为，**但该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。**

【注意】此处的“强制性规定”**限于“效力性强制性规定”**。效力性强制性规定主要包括：

涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策的；

交易标的禁止买卖的，如禁止人体器官、毒品、枪支等买卖；违反特许经营规定的，如场外配资合同；

交易方式严重违法的，如违反招投标等竞争性缔约方式订立的合同；交易场所违法的，如，在批准的交易场所之外进行期货交易。

（5）**违背公序良俗**的民事法律行为。

【注意】根据裁判实务归纳的违背公序良俗的行为类型主要包括：

①影响政治安全、经济安全、军事安全等**国家安全**类型；

②影响社会稳定、公平竞争秩序或者损害社会公共利益等**违背社会公共秩序**类型；

③背离社会公德、家庭伦理或者有损人格尊严等**违背善良风俗**类型。

【知识点】无权代理

1.狭义无权代理

狭义的无权代理属于**效力待定**的合同。

（1）本人的追认权：只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。

若被代理人未予追认，则对被代理人不发生效力。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。

【注意 1】未被追认的，善意相对人有权请求无权代理人履行债务或就其受到的损害请求无权代理人赔偿，

但是赔偿的范围不得超过代理行为有效时所能获得的利益。

【注意 2】相对人知道或应当知道代理人无权代理的，相对人和代理人按照各自的过错承担责任。

（2）相对人的保护：

①催告权：相对人可以催告被代理人在收到通知之日起 30 日内予以追认；

②撤销权：合同被追认**“之前”**，“善意相对人”有撤销的权利。

【注意】追认权、撤销权属于形成权，催告权不属于形成权。

2.表见代理

表见代理，是指代理人虽无代理权但表面上有**“足以使相对人相信其有代理权”**而须由本人负授权之责的代理。

（1）表见代理的类型

项目	内容
授权表示型表见代理	即代理人虽事实上未获授权但存在使相对人善意信赖其具有代理权外观的无权代理
权限逾越型表见代理	即代理人超越代理权限范围且存在使相对人善意信赖其未超越代理权限外观的无权代理
权限延续型表见代理	即代理人在代理期限届满后，或者约定的代理事务完成后，又或者代理权被撤销后，且存在使相对人善意信赖其仍具有代理权外观所实施的无权代理

（2）表见代理的效果。

表见代理发生**有权代理**的效果。

【知识点】诉讼时效的中止和中断

中止	概念：暂时停止计算
	时间：中止只能发生在诉讼时效期间的最后 6 个月，**自中止时效的原因消除之日起满 6 个月**，诉讼时效届满。
	中止的事由（客观原因）： ①**不可抗力**； ②无民事行为能力人或限制民事行为能力人**没有法定代理人**，或法**定代理人死亡、丧失代理权、丧失行为能力**； ③继承开始后**未确定继承人或者遗产管理人**； ④权利人**被义务人或者其他人控制**； ⑤其他导致权利人不能行使请求权的障碍。
中断	概念：已经过去的期间清零

	中断的情形（主观原因）： 1.权利人向义务人**提出履行请求**； 包括：①向债务人送交主张权利文书＋债务人在文书上签名、盖章、按指印或虽未签名、盖章、按指印但能够以其他方式证明该文书到达对方当事人的； ②发送信件或数据电文主张权利＋到达对方； ③作为金融机构的当事人，依法或依约从对方账户中扣收欠款本息； ④债务人下落不明，债权人在国家级或下落不明的当事人一方省级有影响的媒体上发布主张权利的公告； ⑤权利人向义务人的代理人、财产代管人或遗产管理人等提出履行请求。 注 1：债权转让的，诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断 注 2：债权人提起代位权诉讼的，应当认定对债权人的债权和债务人的债权均发生诉讼时效中断的效力 2.义务人**同意履行**义务； 包括义务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿计划等承诺或行为。 3.权利人**提起诉讼或申请仲裁**； 如申请支付令、申请破产、申报破产债权、为主张权利而申请宣告义务人失踪或者死亡、申请诉前财产保全、申请诉前临时禁令、申请强制执行、申请追加当事人或者被通知参加诉讼、在诉讼中主张抵销等。

第八章　物权法律制度

【知识点】物权变动

1.物权变动的原因

类型	示例
民事法律行为	如买卖、互易、赠与、遗赠等原因而完成的物权让与行为
民事法律行为之外的法律事实	（1）如房屋建造、先占、附合、混合、加工、继承、无主物的法定取得、标的物消费、标的物灭失及混同等。 【提示】两个物权**有并存必要，即使同归于一人也不发生混同**。 （2）用益物权可因存续期间届满或目的无法实现等原因而消灭
公法上的原因	如公用征收、**没收、罚款**等

2.我国物权变动的立法

不动产	登记	**登记**生效，法律另有规定的除外
	除外	依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记
		合法建造、拆除房屋，自**事实行为成就时**生效
		土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立
		地役权自**地役权合同生效**时设立
动产	交付	**交付**时生效，法律另规定的除外
	登记对抗	船舶、航空器和机动车，未经登记，不得对抗善意第三人
特殊情况	因法院、仲裁机构的法律文书或政府的征收决定，导致物权变动的，自**法律文书或征收决定生效时**发生物权变动的效力	
	因继承取得物权的，自继承开始时发生效力	

3.动产交付

现实交付	直接交对方占有，实践中最常见的交付方式 【视为现实交付】拟制交付，即交付仓单、提单	
观念交付	简易交付	设立和转让前，权利人已经占有该动产，自**民事法律行为生效时**发生效力 【例】买方先借（租）后买，买卖合同生效时物权转移
	指示交付	设立和转让前，第三人占有该动产，**转让请求第三人返还原物的权利** 【例】购买前为第三人占有，约定生效时物权转移
	占有改定	转让时，当事人约定由出让人继续占有该动产，自该**约定生效时**发生效力 【例】卖方先卖后借（租），约定生效时物权转移

【知识点】善意取得制度

适用条件	（1）转让人**无权处分**； （2）受让人**受让**该不动产或者动产**时**是**善意**的； （3）以**合理的价格**受让；

	（4）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人； （5）转让合同有效
法律后果	受让人取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿
善意认定	受让人受让时，不知道转让人无处分权且无重大过失
举证责任	真实权利人承担举证证明责任
不动产受让人恶意认定	应当认定不动产受让人知道转让人无处分权情形： （1）登记簿上**存在有效的异议登记**； （2）预告登记有效期内，**未经预告登记的权利人同意**； （3）**登记簿上已经记载**司法机关或者行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制不动产权利的有关事项； （4）受让人**知道**登记簿上记载的权利主体错误； （5）受让人**知道**他人已经依法享有不动产物权
重大过失认定	（1）真实权利人有证据**证明**不动产受让人**应当知道转让人无处分权** （2）受让动产时，交易的对象、场所或者时机等**不符合交易习惯**的
善意时间	（1）简易交付：转让动产法律行为生效时 （2）指示交付：转让返还原物请求权的协议生效时
交付取得	船舶、航空器和机动车等特殊动产的善意取得
善意取得的排除适用	**（1）转让合同被认定无效** **（2）转让合同被撤销**

【知识点】共有

类型	按份共有	共同共有
概念	共有人按各自确定的份额享有所有权。（**享多大权利，担多大义务**），如 4 人合起来买了个房，各占 1/4 **【规律】非家庭成员：无约定，就按份。** **份额的判断：约定→出资额→等额，大家依份额享有所有权**	（1）数人对同一物平等和不分份额地共同享有所有权（**有福同享，有难同当**） （2）需以共同关系的存在为前提，如：夫妻财产共有、家庭财产共有和遗产分割前的共有。 **【规律】家庭成员：无约定，就共同。**
分割	可以随时请求分割	原则上不得请求分割，仅在共有的基础丧失（如离婚）或者有重大理由需要分割时，可以请求分割
	实物分割——作价分割——拍卖变卖分割	

设定担保	在其份额上设定担保物权	——
重大变更（处分、重大修缮、变更性质或用途）	应经占份额 **2/3 以上**的按份共有人同意，另约除外	应经**全体共有人一致**同意，另约除外
债权债务	**对外**：共有人对外享有**连带债权**、承担**连带债务**，但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外，如第 10 章中不属于夫妻共同债务的情形	
	对内：除共有人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务，共同共有人共同享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿（**约定→份额/共同**）	
优先购买权	（同等条件下）享有优先购买权	存续期间，共同共有人无优先购买权
	两个以上其他共有人主张行使优先购买权的：协商→转让时共有份额比例 排除适用：**继承、遗赠；按份共有人之间转让共有份额（都是另约除外）**	
	行使期间：有约定的，按约定，否则 （1）转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行使期间的，以该期间为准 （2）通知中未载明行使期间，或者载明的期间短于通知送达之日起 15 日的，为 15 日；转让人未通知的，为其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件之日起 15 日 （3）转让人未通知，且无法确定其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件的，为共有份额权属转移之日起 6 个月 **规律：通知期间－实际 15 日－知应知 15 日－6 个月**	

【知识点】抵押权

（一）抵押财产的范围

1.抵押的财产范围：

（1）建筑物和其他土地附着物

（2）建设用地使用权

（3）海域使用权

（4）生产设备、原材料、半成品、产品

（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器

（6）交通运输工具

（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产

2.禁止抵押财产：

（1）土地所有权

（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

【注意】法律规定可以抵押的除外

（3）学校、幼儿园、医疗机构等以公益为目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施

（4）所有权、使用权不明或有争议的财产

（5）依法被查封、扣押、监管的财产

（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产

（二）抵押登记

类型	范围	效力
不动产：登记生效	（1）建筑物和其他土地附着物 （2）建设用地使用权 （3）海域使用权 （4）正在建造的建筑物	（1）抵押权自**登记之日**起设立 （2）未办理登记，不影响抵押合同生效
动产： 登记对抗	（1）生产设备、原材料、半成品、产品 （2）正在建造中的船舶、航空器 （3）交通运输工具	（1）抵押权自**抵押合同生效时**设立 （2）未经登记，不得对抗善意第三人 （3）动产抵押，**不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押物的买受人**

（三）抵押权的效力

1.范围

有约定按约定，没有约定包括**“主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用”**。

2.抵押权所及标的物的范围

抵押权及于抵押财产本身及其从物、从权利；及于抵押财产被法院依法扣押期间产生的孳息；及于抵押财产因加工、附合、混合形成的添附物；及于抵押财产因侵权行为、保险事故、征收、添附等原因毁损、灭失所获得的赔偿金、补偿金、保险金等代位物。

3.抵押权人的权利

变价处分权；优先受偿权；抵押财产价值保全权；抵押权的处分权。

4.抵押人的权利

（1）抵押财产的用益权。

抵押权设立后，抵押人仍保有对抵押财产的占有，仍可以对抵押财产进行使用和收益。

（2）抵押财产的处分权。抵押人转让抵押财产的,应当及时通知抵押权人。抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

5.重复抵押时的清偿顺序

（1）已登记的，优于未登记的清偿：**登记＞未登记**；

（2）均已登记的，按照**登记时间的先后顺序**清偿；

（3）未登记的，按**债权比例**清偿（不是按抵押合同订立的先后）。

6.抵押权的物上代位效力

担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。

被担保债权的履行期限未届满的，也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

7.抵押权的追及效力

抵押期间，抵押人**可以转让**抵押财产。当事人另有约定的,按照其约定。抵押财产转让的，**抵押权不受影响。**抵押权追及效力的法律限制：

（1）**善意取得**制度：第三人善意取得抵押财产的，可以阻断抵押权的追及效力。

（2）抵押权**未按法定方式公示**：未按法定方式公示的抵押权不得对抗善意第三人。

（3）**正常经营买受人规则**：以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人。

【注意】买受人在出卖人正常经营活动中通过支付合理对价取得已被设立担保物权的动产，担保物权人请求就该动产优先受偿的，人民法院不予支持，但是有下列情形之一的除外：

①购买商品的**数量明显超过一般买受人**；

②**购买**出卖人的**生产设备**；

③订立买卖合同的目的在于**担保出卖人或者第三人履行债务**；

④买受人与出卖人存在**直接或者间接的控制关系**；

⑤买受人应当查询抵押登记而未查询的其他情形。

8.抵押权的优先效力

（1）一般规则：**（登记）时间在先，效力优先**。

（2）特殊规则：购置款超级优先权

动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物**交付后 10 日内**办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，**但是留置权人除外。**

【注意】担保人在设立动产浮动抵押并办理抵押登记后又购入或者以融资租赁方式承租新的动产，下列权利人为担保价款债权或者租金的实现而订立担保合同，并在该动产交付后 10 日内办理登记,主张其权利优先于在先设立的浮动抵押权的,人民法院应予支持:

①在该动产上**设立抵押权或者保留所有权的出卖人**；

②为价款支付**提供融资**而在该动产上**设立抵押权**的债权人；

③以**融资租赁方式出租**该动产的出租人。

同一动产上存在多个价款优先权的，人民法院应当按照登记的时间先后确定清偿顺序。

【知识点】数种担保并存时的效力

1.抵押权、质权、留置权并存

并存	处理
抵押权＋质权	同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照**登记、**

	交付的时间先后确定清偿顺序
抵押权＋留置权； 质权＋留置权	同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，**留置权人优先受偿**

2.担保物权＋保证并存

类型		处理
有约定		按约定实现债权
没有约定或约定不明	**债务人自己提供物的担保**	债权人应当先就该物的担保实现债权
	第三人提供物的担保	债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿

3.保证+保证并存

担保人之间可以相互追偿	（1）担保人之间约定相互追偿及分担份额，承担了担保责任的担保人可以请求其他担保人按照约定分担份额（**可直接追其他担保人**） （2）担保人之间约定承担连带共同担保，或者约定相互追偿但是未约定分担份额的，各担保人按照比例分担向债务人不能追偿的部分（**先追债务人，再追其他担保人**） （3）担保人之间未对相互追偿作出约定且未约定承担连带共同担保，但是各担保人在同一份合同书上签字、盖章或者按指印，承担了担保责任的担保人可以请求其他担保人按照比例分担向债务人不能追偿部分（**先追债务人，再追其他担保人**）
担保人之间不得相互追偿	除上述规定的情形外，承担了担保责任的担保人请求其他担保人分担向债务人不能追偿部分的，法院不予支持

【知识点】占有的分类

占有，是指人对物进行管领和控制的事实。《民法典》将占有作为一种事实状态予以保护。

标准	分类	意义
根据有无占有权源划分	有权占有：合同占有	（1）有权占有人可拒绝他人为本权的行使，无权占有人负有返还义务 （2）基于侵权行为占有他人之物，无留置权发生的效果
	无权占有：遗失物的占有	
根据**是否知其无占有的权源**划分	善意占有	（1）善意取得须以善意受让为要件 （2）回复义务区分善意占有与恶意占有而有所不同
	恶意占有	
根据是否具有所有的意思划分	自主占有：买受、窃取占有	先占及占有物毁损灭失时占有人的赔偿责任范围等，均对自主占有和他主占有有不同的具体要求
	他主占有：借用、质押占有	
根据占有人在事实上	直接占有：质权	（1）**间接占有不能独立存在，直接占有可以独立存**

是否直接占有直接划分	人、保管人	在
	间接占有：出质人、出租人	（2）对占有的保护，有时仅限于直接占有人 （3）使动产的交付能依占有改定而进行，便于交易

第九章　债权法律制度

【知识点】债的保全

（一）代位权

1.债权人代位权的行使条件

（1）债务人怠于行使其债权以及与该债权有关的从权利。

【注意】**“怠于行使”权利是指债务人不履行其对债权人的到期债务，又不以诉讼或仲裁方式向相对人主张其享有的债权或者与该债权有关的从权利。**

（2）须有保全到期债权的必要。

（3）须债权人的债权已届履行期。

【注意】**法律另有规定的，不受“到期”条件限制。**

如民法典规定，债权人的债权到期前，债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形，影响债权人的债权实现的，债权人可以代位向债务人的相对人请求其向债务人履行、向破产管理人申报或者作出其他必要的行为。

2.债权人代位权的行使

代位权的行使	具体规定
（1）行使方法	必须通过**诉讼**方式行使
（2）行使范围	以债务人的债权额和债权人的债权额为限
（3）行使权利	以非专属于债务人自身的权利为限
（4）行使费用	**债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担**

【注意】专属于债务人自身的权利包括：

①**抚养费、赡养费或者扶养费**请求权；

②**人身损害**赔偿请求权；

③**劳动报酬**请求权，但是**超过**债务人及其所扶养家属的生活**必需费用的部分除外**；

④请求支付**基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金**等保障当事人基本生活的权利；

⑤其他专属于债务人自身的权利。

3.债权人代位权行使的效力

（1）债权人接受债务人的相对人履行后，债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。

（2）相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。

（二）撤销权

1.债权人撤销权的行使条件

（1）须有债务人将财产赠与他人、放弃债权、为他人债务提供担保、放弃债权担保、恶意延长到期债权的履行期限、以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产、以明显不合理的价格实施互易财产、以物抵债、出租或者承租财产、知识产权许可使用等**减少其财产或者增加其财产负担的行为**。

【合同编通则解释】转让价格未达到交易时交易地的市场交易价或者指导价 70%的，一

般可以认定为**“明显不合理的低价”**；

受让价格高于交易时交易地的市场交易价或者指导价 30%的，一般可以认定为**“明显不合理的高价”**。

债务人与相对人存在亲属关系、关联关系的，不受前款规定的 70%、30%的限制。

（2）债务人减损责任财产的行为，将导致债权不能实现。

（3）须债务人的行为在债权成立之后所为。

（4）**对于有偿行为，须债务人于行为之际主观上存有恶意且须债务人的相对人知道或者应当知道债务人的该恶意。对于债务人的无偿行为，则无须主观要件。**

2.债权人撤销权的行使规则

撤销权的行使	具体规定
（1）行使方法	以债权人自己的名义起诉
（2）行使期限	应当自债权人**知道或者应当知道**撤销事由之日起 **1 年内**行使，但自债务人**行为发生之日**起 **5 年内**不行使的，撤销权消灭
（3）行使范围	以债权人的债权额为限
（4）行使费用	因行使撤销权而支出的必要费用，由债务人负担

3.债权人撤销权行使的效力

（1）债务人的处分行为因债权人撤销权的行使而被撤销的，自始没有法律约束力。

（2）债务人的处分行为被撤销后，第三人因该行为取得的财产**应返还债务人**。

（3）行使撤销权的债权人，有权请求第三人返还财产，**但就收取的财产并无优先受偿权。**

【知识点】保证

保证合同	合同当事人以外的第三人向债权人担保债务人履行合同义务的协议
特征	单务、无偿、诺成、要式、从合同
合同形式	（1）可以是单独订立的书面合同，也可以是主债权债务合同中的保证条款 （2）第三人**单方以书面形式**向债权人作出保证，债权人**接收且未提出异议**的，保证合同成立
合同变更	（1）**转债权，应通知保证人；转债务，经保证人同意，另有约定除外** （2）第三人加入债务或擅自变更履行期限，保证不受影响 （3）**擅自变更主债权债务，减轻按变更后，加重按变更前**
保证人	（1）**机关法人**不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外 （2）以**公益为目的**的非营利法人、非法人组织不得为保证人
保证方式	一般保证、连带责任保证
	保证方式没约或约定不明的，按一般保证（有先诉抗辩权） 一般保证人失去先诉抗辩权：**（1）债务人下落不明，且无财产可供执行；（2）法院已经受理债务人破产案件；（3）债权人有证据证**

	明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；（4）保证人书面表示放弃先诉抗辩权	
保证范围	（1）有约定，按约定 （2）无约定：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用	
保证期间	不变期间，不发生中断、中止、延长	
	（1）有约定，按约定 （2）无约定、约定不明：自主债务履行期限届满日起 **6 个月**；履行期没约或约定不明，自宽限期届满之日 6 个月 （3）纳税保证期间自纳税人缴纳税款期限届满之日 60 日 【提示】债权人与保证人约定的保证期间**早于主债务履行期或与主债务履行期同时届满，视为没有约定**	
诉讼时效	（1）一般保证：从保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日 （2）连带责任保证：从债权人请求保证人承担保证责任之日	
共同保证	（1）同一债务有 2 个以上保证人，**按约定的保证份额**，承担保证责任 （2）**没有约定**份额，债权人**可以请求任何一个保证人**在其保证范围内承担保证责任	
共同担保	没约或约定不明，债务人自己提供的物的担保的，应当先就该物的担保实现债权（**先物保后人保**）	担保人承担责任后，有权向债务人追偿
	没约或约定不明，第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任（**物保人保没先后**）	
最高额保证	约定在最高债权额限度内就一定期间连续发生的债权提供保证	

【提示】保证合同无效的法律责任

主合同	保证合同	债权人	保证人	责任承担
有效	无效	有过错	有过错	保证人承担≦不能清偿债 1/2
		无过错	有过错	保证人承担债务人不能清偿部分
		有过错	无过错	保证人不承担责任
无效	无效	——	无过错	保证人不承担责任
		——	有过错	保证人承担≦不能清偿部分 1/3
【速记】**保证人无过错不担责；从合同无效，两人有错担 1/2，自己有错补充；主从合同无效，有错担 1/3**				

【知识点】双务合同履行中的抗辩权

同时履行抗辩权	主张当事人	双务合同的双方当事人
	主张事由与方式	（1）双务合同，**没有先后履行顺序**，应同时履行。 （2）若一方未履行或履行不符合约定，对方可拒绝其相应的履行要求
后履行抗	主张当事人	后履行一方

辩权	主张事由与方式	（1）双务合同，**有先后履行顺序** （2）先履行一方未履行或履行不符合约定，**后履行方可拒绝**其相应的履行要求
不安抗辩权	主张当事人	先履行一方
	主张事由与方式	双务合同，应当先履行一方**有确切证据证明**对方存在下列情形之一，可以中止履行： （1）**经营状况严重恶化**； （2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务； （3）**丧失**商业**信誉**； （4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 **规律：对方不能还债**
	行使效力	（1）当事人依法中止履行的，应及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行。 （2）中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。 （3）当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

【知识点】债的移转

1.债权让与

债权让与	应当通知债务人，**通知到达债务人时**对债务人生效
	让与人未通知债务人，受让人直接起诉债务人，法院审理确认债权转让事实，债权转让自起诉状副本送达时对债务人生效
不得转让	（1）根据债权性质不得转让（**抚养、赡养请求权、雇佣债权**） （2）按照当事人约定不得转让（**非金钱债权，不得对抗善意第三人；金钱债权，不得对抗第三人**） （3）依照法律规定不得转让（**精神损害抚慰金请求权**）
法律后果	（1）受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外
	（2）债务人接到通知后，债务人对让与人的抗辩，**可以向受让人主张**
多重让与	（1）让与人将同一债权转让给两个以上受让人，债务人以已经向最先通知的受让人履行，可以主张其不再履行债务。 （2）债务人明知接受履行的受让人不是最先通知的受让人，最先通知的受让人可以请求债务人继续履行或者依据债权转让协议请求让与人承担违约责任。 （3）最先通知的受让人不得请求接受履行的受让人返还其接受的财产，但明知在受让前已经转让给其他受让人除外。

	【最先通知的受让人】**最先到达债务人的转让通知中载明的受让人**

2.债务承担

债务承担	应当经债权人同意，债权人合理期限内未作表示的，视为不同意
债务加入	【加入条件】第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人**未在合理期限内明确拒绝**的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。
	【追偿权】第三人与债务人约定追偿权，履行债务后可以主张向债务人追偿；没有约定追偿权，可以依据不当得利请求债务人向其履行，但第三人知道或应当知道加入会损害利益除外。
法律后果	（1）新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩 （2）原债务人对债权人享有债权的，**新债务人不得向债权人主张抵销** （3）新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但是该从债务专属于原债务人的除外
【债权债务的概括移转】当事人一方**经对方同意**，可以将自己在合同中的权利和义务**一并转让**给第三人，如法定继承、法人合并	

【知识点】合同的订立

（一）要约

1.要约的构成要件

（1）要约须是特定人作出的意思表示。

（2）要约须向要约人希望与之订立合同的相对人发出。

（3）要约的内容具体确定。

（4）要约须是受相对人承诺拘束的意思表示。

2.要约与要约邀请

类型	含义	判断要点
要约	希望和他人订立合同的意思表示	（1）要约人发出，**内容具体确定**。 （2）经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束
要约邀请	希望他人向自己发出要约	（1）一定是要约邀请：拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书寄送的价目表。 （2）**要约邀请或要约：商业广告和宣传**

3.要约与承诺的生效时间

（1）要约生效的时间

方式	生效时间
以对话方式作出的要约	受要约人**知道**其内容时生效
以非对话方式作出的要约	**到达**受要约人时生效

以非对话方式作出的采用数据电文形式的要约	指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效
	未指定特定系统的，受要约人知道或应当知道该数据电文进入其系统时生效

（2）以通知方式作出的承诺，生效的时间同要约。

承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。

4.要约的撤回与撤销

项目	要求
要约的撤回	撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人
要约的撤销	（1）撤销要约的意思表示以对话方式作出，该意思表示的内容应当在受要约人作出承诺前为受要约人所知 （2）撤销要约的意思表示以非对话方式作出，应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人

【提示】不得撤销要约情形：

（1）要约人确定了承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销。

（2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作。

5.要约的失效

（1）要约被拒绝。

（2）要约依法被撤销。

（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺。

（4）受要约人对要约的内容作出“实质性”变更。

【提示】有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等内容的变更，是对要约内容的实质性变更。

（二）承诺

1.承诺的构成要件

（1）承诺须由受要约人向要约人作出。

（2）承诺的内容应当与要约的内容一致。

（3）承诺须在承诺期限内到达要约人。

2.承诺的撤回

撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。

3.承诺的迟到与迟延

界定	一般	例外
迟到：超过承诺期限发出或期内发出但通常不能及时到达	新要约	除非要约人及时通知承诺有效。即“原则无效，例外有效”
迟延：承诺期限内发出，通常能及时到达，其他原因导致期满后才到	承诺有效	除非要约人及时表示不接受。即“原则有效，例外无效”

【知识点】买卖合同

1.一般规定

概念	转移标的物的所有权于买受人，诺成、双务、有偿合同
卖方义务	（1）按约定交货或提货单证及资料，转移所有权 （2）瑕疵担保义务，包括品质瑕疵担保义务和权利瑕疵担保义务
买方义务	付款、领货和法定或约定期间验货
孳息归属	**交付之前**产生的孳息，归**出卖人**所有；**交付之后**产生的孳息，归**买受人**所有，另约定除外
从物	主物转让的，从物随主物转让，法定或另约定除外

2.风险负担

一般情况	标的物毁损、灭失的风险，在标的物**交付之前由出卖人**承担，**交付之后由买受人**承担，法定或另约定除外
买受人违约	因买受人的原因致使标的物未按约定期限交付，买受人**自违反约定时**起承担风险
	按约定或依规定将标的物置于交付地点，买受人违约没有收取的，风险**自违反约定时**起由买受人承担
	【提示】标的物不符合质量，**致使不能实现合同目的，**买受人可以拒绝接受标的物或解除合同，风险由出卖人承担
在途标的物	毁损、灭失的风险自**合同成立时**起由买受人承担，另约定外
交付承运人	按约定将标的物运送至买受人**指定地点并交付给承运人后**，风险由买受人承担
	没约交付地点或约定不明，标的物需要运输的，出卖人将标的物**交付给第一承运人后**，风险由买受人承担
单证资料	未交付单证和资料，不影响风险转移

3.买卖合同的特殊解除规则

主物、从物	（1）因标的物的主物不符合约定而解除合同的，**解除合同的效力及于从物** （2）因标的物的从物不符合约定被解除的，**解除的效力不及于主物**
数物	标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除。但是，该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，买受人可以就数物解除合同
分批交付	（1）一批不交付或者交付不符合约定，**致使该批标的物不能实现合同目的的，**买受人可以就该批标的物解除 （2）一批不交付或者交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除 （3）一批标的物解除，该批与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除

分期付款	（1）买受人**未支付到期价款**达到全部价款 **1/5**，**催告后**合理期限内仍未支付，出卖人可以请求买受人支付**全部价款或者解除合同** （2）出卖人解除合同的，可以向买受人请求支付该标的物的使用费

4.所有权保留买卖合同

概念	约定买受人未履行支付价款或其他义务，标的物的所有权属于出卖人
适用对象	适用于动产，**不适用于不动产**
效力	（1）未经登记，不得对抗善意第三人 （2）利益、风险及责任随交付而移转
出卖人取回权	（1）买受人未按约定支付价款，经催告后在合理期限内仍未支付 （2）未按照约定完成特定条件 （3）将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分
取回权受限	**（1）买受人已经支付标的物总价款的 75%以上，不得主张取回** （2）上述情形（3），第三人已经善意取得标的物所有权或者其他物权，不得主张取回

5.凭样品买卖合同

样品封存	应当封存样品并可以对质量说明，交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同
隐蔽瑕疵	买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，质量仍应当符合同种物的通常标准

6.试用买卖合同

试用期	（1）当事人可以约定试用期限 （2）没约定或约定不明，依据规定仍不能确定的，由出卖人确定
视为购买	试用期满，买受人对是否购买标的物**未作表示**的，**视为购买**
	买受人在试用期内已支付部分价款或对标的物出卖、出租、设立担保物权，视为同意购买
使用费	没约或约定不明，出卖人无权请求买受人支付
风险	标的物在试用期内毁损、灭失的风险由出卖人承担

【知识点】侵权责任的归责原则

类型	概念	举证	适用
过错责任原则	行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任	原告	网络用户、网络服务提供者责任；教育机构责任（限制民事行为能力人）
过错推定责任原则	推定行为人有错，行为人不能证明自己没错，就应承担侵权责任	被告	教育机构责任（无民事行为能力人）；抛掷物和坠落物件损害责任；动物园动物损害责任；建筑物损害责任（一般情况）

无过错责任原则	无论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任	无须	环境污染、生态破坏责任；饲养动物；监护人责任；高度危险作业；产品责任

【知识点】法律特别规定的侵权责任类型

监护人责任	法定监护	无民事、限制民事行为能力人造成他人损害的，由**监护人承担侵权人应承担的全部责任**（无过错责任）。未成年子女造成他人损害，由父母共同承担侵权责任。**夫妻离婚后，未成年子女造成他人损害，由离异夫妻共同承担侵权责任。**一方以未与该子女共同生活为由主张不承担或者少承担责任的，人民法院不予支持。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。
	委托监护	无民事、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，监护人承担侵权人应承担全部责任；受托人在过错范围内与监护人共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额（**受托人过错责任**）
雇主责任	与用人单位形成劳动关系的工作人员、执行用人单位工作任务的其他人员，因执行工作任务造成他人损害，由用人单位承担侵权责任。（**用人单位无过错责任**）	
劳务派遣	劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权人应承担的全部责任；劳务派遣单位在不当选派工作人员、未依法履行培训义务等过错范围内，与接受劳务派遣的用工单位共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。劳务派遣单位先行支付赔偿费用后，就超过自己相应责任的部分可以向接受劳务派遣的用工单位追偿。	
承揽人、定作人责任	承揽人在完成工作过程中因过错造成第三人损害，由**承揽人承担侵权人应承担的全部责任。** **定作人**在定作、指示或者选任**过错范围内**与承揽人共同承担责任，但责任主体实际支付的赔偿费用总和不应超出被侵权人应受偿的损失数额。 定作人先行支付赔偿费用后，就超过自己相应责任的部分可以向承揽人追偿	
网络侵权责任	网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定	
	网络服务提供者接到通知后，未及时采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施的，对损害的**扩大部分与该网络用户承担连带责任**	
	网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任	
教育机构责任	过错推定责任	无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，**幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任**；但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任
	过错	限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身

	责任	损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担侵权责任
	第三人侵权	无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到教育机构以外的**第三人人身损害，由第三人承担侵权责任**；**教育机构**在人民法院就第三人的财产依法强制执行后仍不能履行的范围内，**承担与其过错相应的补充责任**。第三人不确定的，未尽到管理职责的教育机构先行承担与其过错相应的责任；教育机构承担责任后可以向已经确定的第三人追偿
环境侵权	因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任	
环境侵权第三人过错	因第三人的过错污染环境、破坏生态的，被侵权人可以向侵权人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。**侵权人赔偿后，有权向第三人追偿**	
建筑物、构筑物等倒塌、塌陷致害	建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位**能够证明不存在质量缺陷的除外**	
	因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任	
抛掷物品或坠落物品	从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，由具体侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。 物业服务企业等建筑物管理人未采取必要的安全保障措施防止从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，**未采取必要安全保障措施的物业服务企业等建筑物管理人**在人民法院就具体侵权人的财产依法强制执行后仍不能履行的范围内，**承担与其过错相应的补充责任**	
	民事案件一审法庭辩论终结前仍难以确定具体侵权人的，未采取必要安全保障措施的物业服务企业承担与其过错相应的责任。被侵权人其余部分的损害，由**可能加害的建筑物使用人给予适当补偿**。具体侵权人确定后，可以向其追偿	
堆放物致害	堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任	
公共道路妨碍通行	在公共道路上堆放、倾倒、遗撒妨碍通行的物品造成他人损害的，由行为人承担侵权责任。公共道路管理人不能证明已经尽到清理、防护、警示等义务的，应当承担相应的责任	

第十章　婚姻家庭和继承法

【知识点】离婚制度

（一）协议离婚

项目	内容
双方自愿	离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致的意见
冷静期	（1）自婚姻登记机关收到离婚登记**申请之日起 30 日内**，任何一方**不愿意离婚**的，可以向婚姻登记机关**撤回**离婚登记**申请。** （2）在规定期间**届满后 30 日内**，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；**未申请的，视为撤回离婚登记申请**

（二）判决离婚

（1）人民法院审理离婚案件，**应当进行调解，**如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。

（2）有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：

①**重婚**或者与他人**同居**；

②实施家庭**暴力或者虐待、遗弃**家庭成员；

③有赌博、吸毒等**恶习屡教不改**的；

④因**感情不和分居满 2 年**的。

（3）**一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。**

（4）经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满 1 年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

（5）现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但是**军人一方有重大过错的除外**。

（6）女方在怀孕期间，**分娩后 1 年内或者终止妊娠后 6 个月内**，男方不得提出离婚；但是，女方提出离婚或者人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的除外。

（三）离婚的法律后果

1.离婚后的父母子女关系

（1）离婚后，**不满 2 周岁**的子女，以由**母亲直接抚养为原则**。

（2）**已满 2 周岁**的子女，父母双方对抚养问题**协议不成**的，由人民**法院**根据双方的具体情况，按照**最有利于未成年子女的原则判决**。

（3）父母与子女间的关系不因离婚而消除。

（4）父母一方或者其近亲属等抢夺、藏匿未成年子女，另一方向人民法院申请人身安全保护令或者依法申请人格权侵害禁令的，人民法院依法予以支持。抢夺、藏匿未成年子女一方以另一方存在赌博、吸毒、家庭暴力等严重侵害未成年子女合法权益情形，主张其抢夺、藏匿行为有合理事由的，人民法院应当告知其依法通过撤销监护人资格、中止探望或者变更抚养关系等途径解决。当事人对其上述主张未提供证据证明且未在合理期限内提出相关请求的，人民法院依照人身安全保护令或人格权侵害禁令规定处理。

（5）夫妻分居期间，一方或者其近亲属等抢夺、藏匿未成年子女，致使另一方无法履行监护职责，另一方请求行为人承担民事责任的，人民法院可以参照适用民法典关于离婚后

子女抚养的有关规定，暂时确定未成年子女的抚养事宜，并明确暂时直接抚养未成年子女一方有协助另一方履行监护职责的义务。

（6）离婚诉讼中，父母均要求直接抚养已满两周岁的未成年子女，一方有下列情形之一的，人民法院应当按照最有利于未成年子女的原则，优先考虑由另一方直接抚养：①实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；②有赌博、吸毒等恶习；③重婚、与他人同居或者其他严重违反夫妻忠实义务情形；④抢夺、藏匿未成年子女且另一方不存在本条第一项或者第二项等严重侵害未成年子女合法权益情形；⑤其他不利于未成年子女身心健康的情形。

2.共同财产处理

夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，**按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。**

（1）对夫或妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。

（2）夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等**负担较多义务**的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当**给予补偿**。

具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。

3.共同债务处理

离婚时，**夫妻共同债务，应当共同偿还。**

共同财产不足清偿或者财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成的，由法院判决。夫妻一方未经另一方同意，在网络直播平台用夫妻共同财产打赏，数额明显超出其家庭一般消费水平，严重损害夫妻共同财产利益的，可以认定为民法典相关规定的“挥霍”。另一方请求在婚姻关系存续期间分割夫妻共同财产，或者在离婚分割夫妻共同财产时请求对打赏一方少分或者不分的，人民法院应予支持。

夫妻对婚姻关系存续期间所得的**财产约定归各自所有**，夫或妻一方对外所负的债务，**相对人知道该约定的**，以夫或者妻一方的**个人财产清偿**。

4.离婚损害赔偿

有下列情形之一，导致离婚的，**无过错方有权请求损害赔偿**：

①**重婚**；

②与他人**同居**；

③实施**家庭暴力**；

④**虐待**、**遗弃**家庭成员；

⑤有其他重大过错。

【知识点】法定继承

（一）法定继承的适用范围

遗嘱继承优先于法定继承适用。在下列情况下，遗产中的有关部分按照法定继承办理：

（1）遗嘱继承人放弃继承或者受遗赠人放弃受遗赠的。

（2）遗嘱继承人丧失继承权或者受遗赠人丧失受遗赠权。

（3）遗嘱继承人、受遗赠人先于遗嘱人死亡或者终止。

（4）遗嘱无效部分所涉及的遗产。

（5）遗嘱未处分的遗产。

（二）法定继承人的继承顺序

1.第一顺序的法定继承人

配偶、子女（婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女）、父母（生父母、养父母和有扶养关系的继父母）、**对公婆或岳父母尽了主要赡养义务的丧偶儿媳或女婿。**

2.第二顺序的法定继承人

兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

（三）代位继承

1.代位继承的条件

（1）代位继承人包括**被继承人的子女的直系晚辈血亲或者被继承人的兄弟姐妹的子女**（前提是该兄弟姐妹有继承权）。

（2）代位继承人作为第一顺序继承人参加继承，只能继承被代位人应继承的遗产份额。

（3）**继承人丧失继承权的，其晚辈直系血亲不得代位继承。**

2.代位继承的规定

（1）被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。

（2）被继承人的孙子女、外孙子女、曾孙子女、外曾孙子女都可以代位继承，**代位继承人不受辈数的限制。**

（3）被继承人的养子女、已形成扶养关系的继子女的生子女可以代位继承；被继承人亲生子女的养子女可以代位继承；被继承人养子女的养子女可以代位继承；与被继承人已形成扶养关系的继子女的养子女也可以代位继承。

（4）代位继承人缺乏劳动能力又没有生活来源，或者对被继承人尽过主要赡养义务的，分配遗产时，可以多分。

（5）丧偶儿媳对公婆、丧偶女婿对岳父母，无论其是否再婚，依照民法典规定作为第一顺序继承人时，**不影响其子女代位继承。**

（四）转继承

（1）转继承，是指继承人**在继承开始之后，遗产分割之前，未实际取得遗产**而死亡或者被宣告死亡，其应继承份额转由其法定继承人继承。

（2）转继承与代位继承的区别

项目	区别
性质不同	转继承是在继承开始，继承人直接继承后，又转给转继承人继承被继承人的遗产，转继承具有连续继承的性质，转继承发生两次继承
	代位继承只发生一次继承
发生时间和成立条件不同	转继承发生在继承开始后遗产分割前，并且**任何一个继承人都可能成为被转继承人**
	代位继承的前提只能是被代位继承人先于被继承人死亡而发生
主体不同	转继承人是被转继承人死亡时生存的所有法定继承人，被转继承人可以是被继承人的任一继承人
	代位继承中的代位继承人只能是被代位继承人的直系晚辈血亲，其他法定继承人不能成为代位继承人

适用范围不同	转继承可以发生在法定继承中，也可以发生在遗嘱继承中
	代位继承只适用于法定继承，在遗嘱继承中不适用

（五）应继份与酌情分得遗产

（1）同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。

（2）继承人协商同意的，也可以不均等。在下列情况下，同一顺序的法定继承人的份额可以不均等：

a.对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。

b.对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。

c.有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。

（3）非继承人酌情分得遗产的权利。

对继承人以外的依靠被继承人扶养的人，或者继承人以外的对被继承人扶养较多的人，可以分给他们适当的遗产。

【知识点】遗嘱继承

遗嘱形式	自书遗嘱、代书遗嘱、打印遗嘱、录音录像遗嘱、口头遗嘱、公证遗嘱 【提示】除自书遗嘱、公证遗嘱外，其他形式的遗嘱都需要 2 个以上见证人
不能作为遗嘱见证人	（1）无民事、限制民事行为能力人以及其他不具有见证能力的人； （2）继承人、受遗赠人； （3）与继承人、受遗赠人有利害关系的人
遗嘱无效	（1）无民事或者限制民事行为能力人所立的遗嘱；（2）受欺诈、胁迫所立的遗嘱；（3）伪造的遗嘱；（4）遗嘱被篡改的，篡改的内容无效；（5）处分了国家、集体或者他人财产的，该部分无效 【提示】遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额
遗嘱不生效	（1）遗嘱继承人、受遗赠人先于被继承人死亡，但遗嘱另有规定的除外，如指定有候补继承人或者候补受遗赠人；（2）遗嘱继承人、受遗赠人在遗嘱成立之后丧失继承权或者受遗赠权；（3）附解除条件的遗嘱，在遗嘱人死亡之前该条件已经成就；（4）附停止条件的遗嘱，遗嘱继承人、受遗赠人在条件成就前死亡；（5）遗嘱人死亡时，遗嘱处分的财产标的已经不复存在
遗嘱的撤回、变更	（1）遗嘱人可以撤回、变更自己所立遗嘱；（2）立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为撤回；（3）立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准
附义务遗嘱	继承人或受遗赠人没有正当理由不履行义务，经利害关系人或者有关组织请求，法院可以取消其接受附义务部分遗产的权利。

遗嘱执行	（1）遗嘱人可以在遗嘱中指定一个或数个法定继承人、法定继承人以外的人、某些单位或组织执行遗嘱；（2）如果遗嘱人没有指定遗嘱执行人，则全体继承人都可以参加执行遗嘱

【知识点】遗产的处理

遗产归属	继承开始后，遗产转归全体继承人**共同共有**。没有特殊约定的，遗产的适用、收益和处分应当由全体继承人共同为之或者经全体继承人**一致同意**才能进行
遗产管理人的选任	（1）继承开始后，遗嘱执行人为遗产管理人；（2）没有遗嘱执行人的，继承人应当及时推选遗产管理人；（3）继承人未推选的，由继承人共同担任遗产管理人；（4）没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人
	对遗产管理人有争议，利害关系人可以向法院（**被继承人死亡时住所地或主要遗产所在地基层法院**）申请指定遗产管理人
遗产管理人的职责	①清理遗产并制作遗产清单；②向继承人报告遗产情况；③采取必要措施防止遗产毁损、灭失；④处理被继承人的债权债务；⑤按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产 【提示】遗产管理人可以依照法律规定或者按照约定获得报酬
遗产分割	（1）继承人可以在**继承开始后随时**请求分割遗产； （2）应当**保留胎儿的继承份额**，如胎儿出生后死亡的，由其继承人继承；如胎儿娩出时是死体的，由被继承人的继承人继承； （3）主要分割方式：实物分割；变价分割；作价补偿分割、保留共有、遗嘱分割等方式 （4）**继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务，继承人放弃继承的，不负清偿责任；** （5）执行遗赠不得妨碍清偿遗赠人依法应当缴纳的税款和债务； （6）**既有法定继承又有遗嘱继承、遗赠的，由法定继承人清偿税款和债务；超过法定继承遗产实际价值部分，由遗嘱继承人和受遗赠人按比例以所得遗产清偿；** （7）无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家所有，用于公益事业；死者生前是集体所有制组织成员的，归所在集体所有制组织所有

第十一章　个人独资企业法

【知识点】个人独资企业的特征与设立

1.个人独资企业的特征

项目	内容
“人”	（1）出资人只能是**一个自然人（中国公民）**
“财”	（2）投资人对企业债务承担无限责任（先企业后个人）
“名、责”	（3）不能独立的承担民事责任：个人独资企业**不具有法人资格**
	（4）能独立从事民事活动

2.个人独资企业的设立

设立条件	（1）投资人为 1 个自然人； （2）有合法的企业名称； （3）有投资人申报的出资； （4）有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件； （5）有必要的从业人员 【提示】**以家庭财产投资只能以一个自然人的名义投资；**名称中不得使用有限、有限责任或公司字样
成立	**营业执照的签发日期**，为个人独资企业成立日期

【知识点】个人独资企业的事务管理

1.管理方式

投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。

2.投资人的内部限制

个人独资企业的投资人对受托人或者被聘用的人员的限制，**不得对抗善意第三人。**

即受托人或者被聘用的人员超出投资人的限制与善意第三人的有关业务交往应当有效（**该限制对外无效，对内有效**）。

3.对受托人的法定限制

（1）不得利用职务上的便利，索取或者收受贿赂。

（2）不得利用职务或者工作上的便利侵占企业财产。

（3）不得挪用企业的资金归个人使用或者借贷给他人。

（4）不得擅自将企业资金以个人名义或者以他人名义开立账户储存。

（5）不得擅自以企业财产提供担保。

（6）**未经投资人同意，**不得从事与本企业**相竞争**的业务。

（7）**未经投资人同意，**不得**同本企业订立合同**或者进行交易。

（8）**未经投资人同意，**不得**擅自**将**企业商标或者其他知识产权转让给他人使用**。

（9）不得泄露本企业的商业秘密。

（10）法律、行政法规禁止的其他行为。

第十二章　合伙企业法

【知识点】合伙企业的财产

1.合伙企业财产的构成

合伙企业的财产包括合伙人的出资（原始财产）、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产（积累财产）。

合伙企业财产独立于合伙人的个人财产，合伙人不能直接支配合伙企业财产。

合伙人在合伙企业清算前，**不得请求分割合伙企业的财产**。但是，《合伙企业法》另有规定的除外。

2.财产份额的处分

合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的，**合伙企业不得对抗善意第三人。**

3.财产份额的转让

项目	内容
对外	（1）除合伙协议另有约定外，普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经**“其他合伙人一致”**同意 （约定→一致同意） （2）合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在**同等条件下**，其他合伙人有**优先购买权**；但是合伙协议另有约定的除外 （约定→优先购买权）
对内	普通合**伙人之间转让**其在合伙企业中的全部或部分财产份额时，**应通知其他合伙人**

4.出质

（1）普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，**须经其他合伙人一致同意**（强制性规定）

（2）**未经其他合伙人一致同意，其行为无效**，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任

【知识点】合伙企业事务的执行

执行方式	（1）全体合伙人共同执行，享有同等的权利 （2）按合伙协议约定或经全体合伙人决定，可以委托一个或数个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务，其他合伙人不再执行 【提示】作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行
权利	（1）普通合伙人在合伙企业中具有平等的管理权、经营权、表决权、监督权和代表权 （2）执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业 （3）不执行合伙事务的合伙人的监督权利 （4）（所有）合伙人查阅企业会计账簿等财务资料的权利

	（5）合伙人有提出异议的权利和撤销委托的权利	
义务	（1）合伙事务执行人向不参加执行事务的合伙人报告企业经营状况和财务状况 （2）合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务（**同业绝对禁止**） （3）合伙人不得同本合伙企业进行交易，合伙协议另约定或经全体合伙人一致同意除外（**自己交易相对禁止**） （4）合伙人不得从事损害合伙企业利益的活动。	
决议表决	一般事项	按合伙协议约定→一人一票经全体合伙人过半数（**＞1/2**） 【提示】**合伙企业法另有规定，从其规定**
	特殊事项	除合伙协议另有约定外，下列事项应经全体合伙人一致同意： （1）改变合伙企业的**名称** （2）改变合伙企业的**经营范围**、**主要经营场所**的地点 （3）处分合伙企业的**不动产** （4）转让或者处分合伙企业的**知识产权**和其他财产权利 （5）以合伙企业名义为他人提供**担保** （6）**聘任合伙人以外的人**担任合伙企业的经营管理人员 【速记】不动产、知识产权、名称、范围、场所、聘外人、担保（谐音：不知名反常拼单）
损益分配	约定→协商→实缴出资比例→平分 【提示】**合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人（有限合伙允许）或者由部分合伙人承担全部亏损（绝对性禁止）**	

【知识点】入伙和退伙

入伙	除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议；原合伙人有义务告知合伙企业经营状况和财务状况	
	新合伙人对**入伙前**合伙企业的债务承担**无限连带责任**	
自愿退伙	协议退伙	合伙协议约定合伙期限的，合伙企业存续期间，有下列情形之一，合伙人可以退伙：（1）合伙协议约定的退伙事由出现；（2）经全体合伙人一致同意；（3）发生合伙人难以继续参加合伙的事由；（4）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务
	声明退伙	合伙协议**未约定合伙期限**的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当**提前 30 日通知**其他合伙人
强制退伙	法定退伙（当然退伙）	（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；（2）个人丧失偿债能力（**有限合伙人除外**）；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被法院强

		制执行 【提示 1】退伙事由**实际发生之日**为退伙生效日 【提示 2】**普通合伙人被依法认定为无民事或限制民事行为能力人，经其他合伙人一致同意，可以转为有限合伙人，普通合伙企业转为有限合伙企业**
	除名退伙	合伙人有下列情形之一，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：（1）未履行出资义务；（2）因故意或者重大过失给合伙企业造成损失；（3）执行合伙事务时有不正当行为；（4）发生合伙协议约定的事由 【提示】被除名人**接到通知之日**，除名生效，有异议可以起诉
退伙结算	（1）按退伙时企业财产状况结算； （2）退还办法由合伙协议约定或全体合伙人决定，可以退还货币、实物； （3）退伙人**对退伙前企业债务，承担无限连带责任**	
继承	【资格继承】合伙人死亡或被依法宣告死亡，按合伙协议约定或经全体合伙人一致同意，继承人可以取得合伙人资格 【财产继承】有下列情形之一，合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙人的财产份额：①继承人不愿意成为合伙人；②法律规定或合伙协议约定合伙人必须具有相关资格，而该继承人未取得该资格；③合伙协议约定不能成为合伙人的其他情形 【提示】**普通合伙人身份不能直接继承，财产可以直接继承**	

【知识点】特殊的普通合伙企业

1.概念

（1）特殊的普通合伙企业：是以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的“专业服务机构”。

（2）特殊的普通合伙企业名称中应当标明**“特殊普通合伙”**字样。

2.特殊的普通合伙企业风险管理

特殊的普通合伙企业应当**建立执业风险基金、办理职业保险**。执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务。执业风险基金应当单独立户管理。

3.责任承担方式

（1）有限责任与无限责任相结合

如果一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中**因“故意或重大过失”**造成合伙企业债务的，该合伙人需承担无限责任或者无限连带责任，而其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

（2）无限连带责任

合伙人在执业活动中**“非因故意或者重大过失”**造成的合伙企业债务，以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

（3）责任追偿

因故意或重大过失造成合伙企业债务的合伙人，在合伙企业对外承担责任后，还需按照合伙协议的约定对合伙企业造成的损失承担赔偿责任。

【知识点】有限合伙企业

一、有限合伙企业的设立

合伙人	人数	2 个以上 50 个以下合伙人设立，法律另有规定除外
	组成	有限合伙企业**至少应当有 1 个普通合伙人** 【提示】有限合伙企业**仅剩有限合伙人，应当解散**；有限合伙企业**仅剩普通合伙人，应当转为普通合伙企业**
	资格	自然人、法人和其他组织可以设立有限合伙企业 【提示】**国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人，可以成为有限合伙人**
出资	出资期限	有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任
	出资形式	有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资，**不得以劳务出资**
名称	有限合伙企业名称中应当标明**“有限合伙”**字样	

二、有限合伙企业的自己交易、竞业、出质与转让

	有限合伙人	普通合伙人
关联交易	可以同本企业进行交易；有约定的除外（**先约定，无约定可以**）	不得同本企业进行交易，有约定或全体合伙人一致同意除外（**先约定或同意，否则不得**）
竞业禁止	可以自营或同他人合作经营与本企业相竞争的义务；有约定除外（**先约定，无约定可以**）	不得自营或同他人合作经营与本企业相竞争的业务（**绝对禁止**）
出质	可以将其财产份额出质；约定的除外（**先约定，无约定可以**）	财产份额出质，须经其他合伙人一致同意（**必须一致同意**）
对外转让	可以向外人转让其财产份额，应提前 30 日通知其他合伙人，其他合伙人有优先购买权（**对外转让需通知**）	除另有约定外，向外人转让财产份额，须经其他合伙人一致同意，其他合伙人有优先购买权（**对外转让需一致同意**）
	【提示】两类合伙人对内转让其财产份额，应当通知其他合伙人	

第十三章　公司法

【知识点】公司投资、担保与财务资助

公司投资	（1）**不得对所投资企业的债务承担连带责任** （2）向其他企业投资，按照公司章程的规定由**董事会或者股东会决议** （3）公司章程对投资总额及单项投资数额有限额规定的，不得超过规定的限额	
公司担保	为公司股东或者实际控制人担保	应当经股东会决议，接受公司担保的股东或受实际控制人支配的股东不得参加表决，由出席会议的其他股东所持表决权的过半数（＞1/2）通过
	为他人担保	按照公司章程的规定由**董事会或者股东会**决议
	上市公司特殊特别决议	上市公司**一年内**购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额 **30%的**，应当由股东会作出决议，**并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过**
财务资助	公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。	
	经股东会决议或者董事会按章程或股东会的授权作出决议，可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。 【提示 1】董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。 【提示 2】视同财务资助情形：（1）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；（2）为他人承担费用；（3）无偿或低价提供资产使用权；（4）支付预付款比例明显高于行业一般水平	

【知识点】公司设立条件

一、公司设立条件

	股份公司		有限公司
方式	发起设立	募集设立	发起设立
人数	发起人为 **1～200 人**（≥1/2 境内有住所） 股东≥1 人		**1～50 人**
注册资本	认购股本总额，且需公司**成立前缴足**	**实收**股本总额 （发起人认购股份≥35%，且需在公司成立前缴足）	认缴资本，自公司成立之日起 **5 年内缴足**
章程	发起人	发起人制订后须**经成立大会通过**	全体股东
公司名称	标明“股份有限公司或者股份公司”		标明“有限责任公司或者有限公司”
公司	主要办事机构所在地		

住所	

二、组织机构

	股东会	董事会	监事会
股份公司	√	√	√
有限公司	√	√	√
注：**以上公司若人数少、规模小，可不设董事会，只设 1 名执行董事；可不设监事会，只设 1 名监事。**			

【知识点】股东出资

（一）出资方式

项目	内容
一般规定	股东可以用**货币**出资，也可以用**实物、知识产权、土地使用权、股权、债权**等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资； 但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外
出资手续	（1）股东以货币出资的：足额存入公司在银行开设的账户 （2）以**非货币财产**出资的，应当**依法办理财产权的转移手续**
股权不得用于出资情形	（1）已被设立质权 （2）股权所在公司章程约定不得转让 （3）法律、行政法规或者国务院决定规定，股权所在公司股东转让股权应当报经批准而未经批准 （4）法律、行政法规或者国务院决定规定不得转让的其他情形
债转股应符合的情形	（1）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或公司章程的禁止性规定 （2）经人民法院生效裁判或者仲裁机构裁决确认 （3）公司破产重整或者和解期间，列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议

（二）出资责任

1.股东、出资人赔偿责任

在公司章程规定期限内，股东或者出资人未按期足额缴纳出资的，除应当向公司**足额缴纳**外，还应当对给公司造成的**损失承担赔偿责任**。

2.连带责任

（1）公司设立时，股东未按照公司章程规定实际缴纳出资或者发起人不按照其认购的股份缴纳股款，股东实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额或者发起人作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的；

设立时的其他股东、其他发起人与该股东、该发起人在出资不足的范围内承担连带责任。

（2）抽逃出资的形态：

①制作虚假财务会计报表**虚增利润**进行分配；

②通过**虚构债权债务关系**将其出资转出；

③利用**关联交易将出资转出**；

④其他未经法定程序将出资抽回的行为。

（3）抽逃出资的民事责任

公司成立后，股东或者出资人违反规定抽逃出资的，**股东或者出资人应当返还抽逃的出资**；给公司造成损失的，负**有责任的董事、监事、高级管理人员**应当与该股东或者该出资人承担**连带赔偿责任**。

（三）股东失权

1.董事的赔偿责任

公司成立后，董事会应当对股东或者出资人的出资情况进行核查，发现股东或者出资人未按期足额缴纳公司章程规定的出资的，**应当**由公司向该股东或者出资人**发出书面催缴书**，催缴出资。**未及时履行规定义务给公司造成损失的，负有责任的董事应当承担赔偿责任。**

2.失权宽限期

发出书面催缴书催缴出资的，可以载明缴纳出资的宽限期；宽限期自公司发出催缴书之日起，**不得少于 60 日。**

3.股东失权程序

宽限期届满，股东仍未履行出资义务的，公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知，通知应当以书面形式发出。自通知**发出之日起**，该股东**丧失其未缴纳出资的股权**。

丧失的股权应当依法转让，或者相应减少注册资本并注销该股权；6 个月内未转让或者注销的，由公司其他股东按照其出资比例足额缴纳相应出资。

4.股东失权救济

股东对失权有异议的，应当自接到失权通知之日起 30 日内，向人民法院提起诉讼。

（四）出资加速到期

有限责任公司不能清偿到期债务的，公司或者已到期债权的债权人有权要求**已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。**

【知识点】股份（权）转让

1.有限责任公司转让股权

股东之间转让：可以相互转让其全部或者部分股权	
向股东以外的人转让	（1）应**书面通知**其他股东（转让数量、价格、支付方式和期限），其他股东在同等条件下有优先购买权。 （2）接到书面通知之日**三十日内未答复**，视为**放弃优先购买权**。 （3）两个以上股东行使优先购买权，协商确定购买比例；协商不成，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 （4）章程另有规定，从其规定。
法院强制转让	应**通知公司及全体股东**，其他股东同等条件有优先购买权。自法院通知之日 20 日不行使，视为放弃优先购买权
【提示】受让人**自记载于股东名册时，可以行使股东权利**	

2.股份有限公司转让股份

可以向其他股东或股东以外的人转让	
董、监、高转让限制	①自公司股票**上市交易之日起1年内**不得转让。 ②在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的**25%**。 ③**离职后半年内**，不得转让其所持有的本公司股份。

3.公司收购股权

收购情形	有下列情形之一，对股东会该项决议**投反对票的股东**可以请求公司按照合理的价格收购其股权，**公开发行股份的公司除外**： （1）公司连续5年盈利且符合公司法规定的分配利润条件但不向股东分配利润； （2）**有限责任公司合并、分立；** （3）公司转让主要财产； （4）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续。 【提示1】**有限责任公司的控股股东**滥用股东权利，严重损害公司或其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。 【提示2】公司收购本公司股权，应在**6个月内**转让或者注销。

【知识点】股东诉权

1.涉及撤销的诉讼

决议可撤销	有限责任公司股东会、董事会的会议**召集程序、表决方式**违反法律、行政法规或者公司章程，或者**决议内容**违反公司章程
	股东自决议作出之日（未被通知参加的股东自知道或者应当知道之日）60日内，可请求法院撤销
	自决议作出之日起**1年内没有行使，撤销权消灭**
	【提示】召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外

2.涉及股东知情权的诉讼

股东知情权	（1）股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出**书面请求，说明目的** （2）公司拒绝提供查阅的，股东可以请求法院要求公司提供查阅 （3）公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由
不正当目的	（1）股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系业务的，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外 （2）股东为了向他人通报有关信息查阅公司会计账簿，可能损害公司合法利益的 （3）股东在向公司提出查阅请求之日前的3年内，曾通过查阅公司会计

	账簿，向他人通报有关信息损害公司合法利益的

3.涉及股东失权的诉讼

具体情形	股东对失权有异议的，应当自**接到失权通知之日起 30 日内**，向人法院提起诉讼

4.涉及解散公司的诉讼

具体情形	公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司**10%以上表决权**的股份有限公司的股东，可以请求人民法院解散公司
不受理	知情权、利润分配请求权等权益受到损害，或者公司亏损、财产不足偿还全部债务，公司被吊销营业执照未进行清算等

5.股东直接诉讼

具体规定	公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，**损害股东利益的**，股东可以（**直接作为原告**）向法院提起诉讼

6.股东代表诉讼

（1）提起股东

有限公司	**任何一个“股东”**（单独股东权）
股份公司	连续 **180 日**单独或合计持有公司 **1%以上股份**的股东

（2）股东对公司或者全资子公司“董监高”提起诉讼程序

董事、高管侵犯公司利益	找求公司或者全资子公司监事会（**必经程序**）
监事侵犯公司利益	找求公司或者全资子公司董事会（**必经程序**）
股东以自己名义起诉	①收到股东书面请求后**拒绝**起诉；②收到请求之日 **30 日内未起诉**；③情况**紧急**，不立即起诉使公司受到难以弥补的损害

（3）股东对“他人”提起诉讼程序

情形	他人侵犯公司或者全资子公司权益，给公司或者全资子公司造成损失
诉讼方式	①可以书面请求董事会或者监事会向法院提起诉讼 ②可以直接向法院提起诉讼

【知识点】公司解散与清算

解散情形	（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现； （2）股东会决议解散； （3）因公司合并或者分立需要解散； （4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （5）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决，持有公司 10%以上表决权的股东，可以请求法院解散
自行	**董事为清算义务人，应当解散事由出现之日起 15 日内成立清算组**

清算	清算组由董事组成，章程另规定或股东会决议另选他人的除外
	【提示】**除合并、分立豁免清算外，其他解散的公司应当清算**
指定清算	利害关系人申请法院指定清算组：（1）逾期不成立清算组进行清算；（2）成立清算组后不清算
清算组职权	（1）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（2）通知、公告债权人；（3）处理与清算有关的公司未了结的业务；（4）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（5）清理债权、债务；（6）分配公司清偿债务后的剩余财产；（7）代表公司参与民事诉讼活动
债权申报	（1）清算组自成立之日起**10日内通知债权人**，并于**60日内**在报纸上或者国家企业信用信息公示系统**公告**。 （2）债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报债权。
清偿顺序	支付清算费用→职工工资、社会保险费用和法定补偿金→缴纳所欠税款→清偿公司债务后的剩余财产→ ◆有限责任公司按照股东的**出资比例**分配 ◆股份有限公司按照股东**持有的股份比例**分配。
申请注销	清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，并报送公司登记机关，申请注销登记
简易注销	【适用情况】公司在存续期间未产生债务，或者已清偿全部债务的，**经全体股东承诺** 【提示】股东承诺不实，对注销登记前的债务承担连带责任
	【程序】应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于20日。公告期限届满后，未有异议，可以在20日内向登记机关申请注销登记。
强制注销	公司被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，满3年未申请注销登记，登记机关可以通过国家企业信用信息公示系统予以公告，公告期限不少于60日。期满后无异议，登记机关可以注销登记。 【提示】原股东、清算义务人的责任不受影响

第十四章　破产法

【知识点】破产申请

<table>
<tr><td rowspan="5">初始申请主体</td><td colspan="2">债务人：不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力</td><td>破产清算、重整、和解</td></tr>
<tr><td rowspan="2">债权人</td><td>债务人不能清偿到期债务</td><td>破产清算、重整</td></tr>
<tr><td>企业法人已解散但未清算或在合理期限内未清算完毕</td><td>破产清算</td></tr>
<tr><td colspan="2">依法负有清算责任的人：企业法人已解散但未清算或者未清算完毕，资产不足以清偿债务
【提示】一般董事为清算责任人</td><td>破产清算</td></tr>
<tr><td colspan="2">国务院金融监管机构：商业银行、证券公司、保险公司等金融机构具有破产原因的</td><td>破产清算、重整</td></tr>
<tr><td rowspan="4">后续申请主体</td><td colspan="3">法院受理破产申请后、宣告破产前</td></tr>
<tr><td>债务人</td><td colspan="2">重整、和解</td></tr>
<tr><td>出资额占债务人注册资本1/10以上的出资人</td><td colspan="2">重整</td></tr>
<tr><td colspan="3">【提示】重整程序限制：债权人首先申请对债务人进行破产清算</td></tr>
</table>

【知识点】管理人职责

基本职责	（1）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；（2）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；（3）决定债务人的内部管理事务；（4）决定债务人的日常开支和其他必要开支；（5）**在第一次债权人会议召开前，决定继续或停止债务人的营业；**（6）管理和处分债务人的财产；（7）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；（8）提议召开债权人会议
特定职责	（1）**对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同，有权决定是否解除或者继续履行；** （2）自法院裁定债务人重整之日起6个月内，向法院和债权人会议提交重整计划草案；由债务人提出重整计划草案的，管理人需监督执行； （3）拟订破产财产变价方案和分配方案； （4）破产申请受理后，经债权人会议决议通过，或者第一次债权人会议召开前经人民法院许可管理人或者自行管理的债务人可以为债务人继续营业而借款
履职要求	（1）管理人依法执行职务，向法院报告工作； （2）管理人应当列席债权人会议，报告职务执行情况，并接受监督、回答询问；

	（3）**在第一次债权人会议召开之前，管理人决定继续或者停止债务人的营业，应当经法院许可；** （4）管理人拟通过清偿债务或者提供担保取回质物、留置物，或者与质权人、留置权人协议以质物、留置物折价清偿债务，进行对债权人利益有重大影响的财产处分行为，应及时报告债权人委员会；未设立债权人委员会，应及时报告法院； （5）管理人**处分的债务人重大财产**，应**事先**制作财产管理或变价方案并**提交债权人会议表决**，表决未通过的，不得处分； （6）确需聘请中介机构对债务人财产进行审计、评估，经法院许可后，可以自行公开聘请。
管理人责任	（1）未依法勤勉尽责，忠实执行职务的，法院可以处以罚款，给债权人、债务人或第三人造成损失的，依法承担赔偿责任 （2）因过错未依法行使撤销权导致债务人财产不当减损，债权人可以提起诉讼主张其赔偿

【知识点】破产债权申报

申报期限	自法院发布受理破产申请公告之日起，**30 日≤申报期限≤3 个月**
补充申报	申报期限内未申报债权，可以在破产财产**最后分配前**补充申报，但此前已进行的分配，不再对其补充分配；为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担
未到期	未到期的债权，在破产申请受理时视为到期
附利息	（1）附利息的债权自破产申请受理时起**停止计息**，债权人可以受理时的本金及截止受理日的利息进行申报 （2）附条件、附期限的债权可以申报，待条件成就或期限届至时再确实是否参与分配
诉讼、仲裁未决的债权	债权人可以申报，待诉讼或仲裁结果确定后处理
欠缴的税款	税务机关可以申报
无担保债权	在破产申请受理前成立的对债务人享有的无财产担保债权，债权人均可申报
有担保债权	就特定财产享有担保权的债权，债权人可以申报，并就该财产优先受偿
连带债权	连带债权人可以由其中一人代表全体连带债权人申报债权，也可以共同申报债权（**申报的债权是连带债权的，应当说明**）
求偿权申报	（1）债务人的保证人或者其他连带债务人**已经代替债务人清偿**债务的，以其对债务人的**求偿权申报债权** （2）债务人的保证人或者其他连带债务人尚未代替债务人清偿债务

	的，以其对债务人的将来求偿权申报债权。但是，债权人已经向管理人申报全部债权的除外（**不得重复申报**）
均未履行完毕	管理人依照破产法规定解除双方均未履行完毕的合同，对方当事人可以合同解除所产生的实际损害赔偿请求权申报债权。违约金不作为破产债权
处理委托事务债权	债务人的受托人可以继续处理委托事务产生的请求权申报债权
票据债权	票据的付款人可以继续付款或者承兑产生的请求权申报债权
连带债务人破产	连带债务人数人被裁定适用企业破产法规定的程序的，其债权人有权就全部债权**分别在各破产案件中申报债权**
保证人破产	保证人被裁定进入破产程序的，债权人有权申报其对保证人的保证债权
	主债务未到期的，保证债权在保证人破产申请受理时**视为到期。**一般保证的保证人主张行使先诉抗辩权的，法院不予支持，但债权人在一般保证人破产程序中的分配额应予**提存**，待一般保证人应承担的保证责任确定后再按照破产清偿比例予以分配
	保证人被确定应当承担保证责任的，保证人的管理人可以**就保证人实际承担的清偿额向主债务人或其他债务人行使求偿权**
保证人、债务人均破产	债务人、保证人均被裁定进入破产程序的，债权人有权向债务人、保证人分别申报债权
	债权人向债务人、保证人均申报全部债权的，从一方破产程序中获得清偿后，其对另一方的**债权额不作调整，但债权人的受偿额不得超出其债权总额。保证人履行保证责任后不再享有求偿权**
税务债权申报	申报主体：税务机类作为债权人，需在人民法院确定的债权申报期限内向管理人申报债权
	申报范围：企业所欠税款（含教育费附加、地方教育附加）、税款滞纳金、罚款以及因特别纳税调整产生的利息，社会保险费及其滞纳金，税务机关征收的法律责任和政策依据明确的非税收入（违约金）
	债权计算时点：以人民法院裁定受理破产申请之日为截止日，计算确定税费债权
	破产程序中产生税费的处理：管理人管理、变卖、分配债务人财产产生的税费，属于破产费用；管理人继.续营业产生的相关税费，属于共益债务。上述税费，均由债务人财产随时清偿。

【知识点】破产费用和共益债务

1.破产费用

破产费用是指为全体债权人的共同利益，在破产程序进行中支出，从债务人财产中拨付的费用。破产费用包括：

（1）破产案件的**诉讼费用**。

（2）管理、变价和分配债务人财产的费用。

（3）管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用。

（4）人民法院裁定受理破产申请的，此前债务人尚未支付的公司强制清算费用、未终结的执行程序中产生的评估费、公告费、保管费等执行费用，可以参照破产法关于破产费用的规定，由债务人财产随时清偿。

【提示】此前债务人尚未支付的案件受理费、执行申请费，可以作为破产债权清偿。

2.共益债务

共益债务是指人民法院受理破产申请后，为了全体债权人的共同利益以及破产程序顺利进行而发生的应由债务人财产负担的债务总称。包括：

（1）因管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务。

（2）债务人财产受无因管理所产生的债务。

（3）因债务人不当得利所产生的债务。

（4）为债务人继续营业而应支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务。

（5）管理人或者相关人员执行职务致人损害所产生的债务。

（6）债务人财产致人损害所产生的债务。

3.清偿顺序

（1）破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。

（2）债务人财产不足以清偿所有破产费用和共益债务的，先行清偿“破产费用”。

（3）债务人财产不足以清偿所有破产费用或者共益债务的，按照“比例清偿”。

（4）如果债务人财产不足以支付破产费用的，管理人应当提请人民法院终结破产程序。

【提示】债务人财产不足以支付所有破产费用，但破产案件的债权人、管理人、债务人的出资人或者其他利害关系人愿意垫付相关费用的，经人民法院同意，破产程序可以继续进行。

【知识点】抵销权

提出主体	债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销 【提示】管理人不得主动抵销债务人与债权人的互负债务，**但抵销使债务人财产受益的除外**
抵销生效	（1）管理人无异议：抵销自管理人收到通知之日起生效 （2）管理人有异议：法院判决驳回管理人提起的抵销无效诉讼请求的，该抵销自管理人收到主张债务抵销的通知之日起生效
异议	管理人异议的，应当在约定的异议期限内或者自收到主张债务抵销的通知之日起 3 个月内向法院提起诉讼。无正当理由逾期提起的，法院不予支持
	管理人下列异议，法院不支持：（1）破产申请受理时，债务人对债权人负有的债务尚未到期；（2）破产申请受理时，债权人对债务人负有的债务尚未到期；（3）双方互负债务标的物种类、品质不同
不得抵销	（1）债务人的债务人在破产申请**受理后取得**他人对债务人的债权的 （2）债权人**已知**债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人负担债务的；但是，**债权人因为法律规定或者有破产申请 1 年前所发**

	生的原因而负担债务的除外 （3）债务人的债务人**已知**债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人取得债权的；**但是，债务人的债务人因为法律规定或者有破产申请 1 年前所发生的原因而取得债权的除外**
抵销无效	破产申请受理前 **6 个月内**，债务人具有破产原因，债务人与个别债权人以抵销方式对个别债权人清偿，其抵销的债权债务属于上述第（2）、（3）项规定的不得抵销的情形之一，管理人在破产申请受理之日起 3 个月内向法院提起诉讼，主张该抵销无效的，法院应予支持
股东抵销限制	债务人的股东主张以下列债务与债务人对其负有的债务抵销，债务人管理人提出异议的，法院应予支持： （1）债务人股东因欠缴债务人的出资或者抽逃出资对债务人所负的债务； （2）债务人股东滥用股东权利或者关联关系损害公司利益对债务人所负的债务

第十五章　电子商务法

【知识点】电子商务合同的订立和履行

<table>
<tr><td>民事行为能力</td><td colspan="2">在电子商务中推定当事人具有相应的民事行为能力，但有相反证据足以推翻的除外</td></tr>
<tr><td>合同成立</td><td colspan="2">电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的，用户选择该商品或者服务并提交订单成功，合同成立。
【提示】不得以格式条款约定消费者支付价款后合同不成立</td></tr>
<tr><td rowspan="7">数据电文发送与接收</td><td>视为发件人发送</td><td>①经发件人授权发送的；②发件人的信息系统自动发送的；③收件人按照发件人认可的方法对数据电文进行验证后结果相符的
【提示】另有约定，从其约定</td></tr>
<tr><td>视为收到</td><td>发件人收到收件人的收讫确认时，视为已经收到</td></tr>
<tr><td rowspan="2">有约定按约定，未约定按以下规定</td><td>【发送时间】数据电文进入发件人控制之外的某个信息系统的时间，视为发送时间</td></tr>
<tr><td>【接收时间】（1）收件人指定特定系统接收数据电文的，数据电文进入该特定系统的时间，视为接收时间；（2）未指定特定系统的，数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为接收时间</td></tr>
<tr><td rowspan="2">有约定按约定，未约定按以下规定</td><td>【发送地点】发件人的主营业地为数据电文的发送地点；没有主营业地的，其经常居住地为发送地点</td></tr>
<tr><td>【接收地点】收件人的主营业地为数据电文的接收地点；没有主营业地的，其经常居住地为接收地点</td></tr>
<tr><td>交付时间有约定按约定，未约按以下规定</td><td>（1）合同标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人签收时间为交付时间
（2）合同标的为提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为交付时间；前述凭证没有载明或载明时间与实际提供服务时间不一致，实际提供服务的时间为交付时间
（3）合同标的为采用在线传输方式交付的，合同标的进入对方当事人指定的特定系统并且能够检索识别的时间为交付时间</td></tr>
<tr><td>自动信息系统</td><td colspan="2">（1）电子商务当事人使用自动信息系统订立或者履行合同的行为对使用该系统的当事人具有法律效力。
（2）因技术故障，未按照预先设定的程序指令、算法、参数与条件运行，导致数据电文未按时传递、传递不完整或者失实，使用自动信息系统的一方当事人应当承担相应的法律后果；给对方当事人造成损失的，应当赔偿。</td></tr>
</table>

	（3）自动信息系统的使用者可以向开发者、提供者追偿。
快递物流提供者义务	（1）有义务提示收货人当面查验快递包裹内件，收货人有权要求查验之后再签收。
	（2）交由他人代收，应经收货人同意；使用智能快件箱、驿站等非合同约定的方式递送，应征得收件人同意，否则构成违约。
	（3）提供快递物流服务的同时，可以接受电子商务经营者的委托提供代收货款服务。

【知识点】电子签名

项目	具体规定
特征	（1）电子签名是以电子形式出现的数据 （2）电子签名表达了签署者的意愿 （3）具有身份识别功能 （4）电子签名具有不可抵赖性
形式	电子签名形式多样，如电子化签名、密码签名、生物特征签名、数字签名等
法律效力	（1）在排除三种特殊情况（包括涉及婚姻、收养、继承等人身关系；停止供水、供热、供气等公用事业服务以及法律行政法规规定的不适用电子文书的其他情形等）的前提下，全面认可了民商事活动中产生的各类电子签名、数据电文的法律效力 （2）当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，不得仅因为其采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力 （3）能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式 （4）可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力 （5）可靠的电子签名应具备的条件： ①电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有 ②签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制 ③签署后对电子签名的任何改动能够被发现 ④签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现 （6）电子签名人的法律义务： ①应当妥善保管电子签名制作数据 ②电子签名人知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密时，应当及时告知有关各方，并终止使用该电子签名制作数据

第十六章　民事诉讼法

【知识点】民事诉讼管辖

（一）级别管辖

最高院	**全国范围内**有重大影响的一审案件＋认为应由自己审理的案件
高院	**本辖区内**有重大影响的一审民事案件
中院	①**重大涉外**案件（包括争议标的额大的案件、案情复杂的案件，或一方当事人人数众多等具有重大影响的案件）； ②在**本辖区**有重大影响的案件； ③最高法院确定由中级法院管辖的案件。
基层	剩下的

【注】专利纠纷案件由**知识产权**法院、**最高法院确定的中级**法院和**基层**法院管辖。海事、海商案件由**海事法院**管辖。

（二）地域管辖

1.一般地域管辖	（1）概念：是指以当事人的住所地与法院辖区的隶属关系来确定的管辖。
	（2）原则：**被告**所在地法院管辖 【注】**公民：被告经常居住地>被告住所地。** 组织：被告主要办事机构所在地
2.特殊地域管辖	指以**当事人住所地、诉讼标的、诉讼标的物所在地，或者引起法律关系发生、变更或者消灭的法律事实所在地**为标准确定的管辖。
3.协议管辖—书面协议	概念：指当事人在争议发生之前或者发生之后，用书面协议的方式，选择管辖法院。
	适用范围：**合同或其他财产权益纠纷**的当事人
	选择范围：**被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点**的法院管辖
	限制：不得违反级别管辖和专属管辖的规定
4.专属管辖—不准当事人协议变更	概念：指基于法律规定，某些案件必须由特定的法院管辖，其他法院无权管辖，也不准许当事人协议变更管辖。
	①因**不动产纠纷**提起的诉讼：不动产所在地。 ②因**港口作业**中发生纠纷提起的诉讼：港口所在地。 ③因**继承遗产纠纷**提起的诉讼：由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地。
5.共同管辖—两个或两个以上法院都有管辖权	**先立先管**：原告同时向两个以上有管辖权的法院起诉，则由最先立案的法院管辖。 **先立不移**：两个以上法院都有管辖权，先立案的不得将案件移

	送给另一个法院。
6. 选择管辖—原告选择	对于共同管辖，当事人可以选择其中一个法院起诉。

小结：共同管辖 VS 选择管辖

	共同管辖	选择管辖
共同点	是一个问题的两个方面	
不同点	从法院角度看，多个法院都有管辖权	从当事人角度看，可从多个有管辖权的法院中择一起诉

（三）移送管辖（纠错）

是指**受理案件后**，发现无管辖权时，将案件移送给有管辖权的法院审理。

（四）指定管辖—上级指定辖区内下级管辖

有管辖权的法院由于特殊原因	不能行使管辖权，由上级法院指定管辖
法院之间因管辖权发生争议，经协商不能解决，由**共同上级指定**管辖	

（五）涉外民事案件的管辖—涉外民事纠纷的管辖

特殊管辖	因涉外民事纠纷，对在国内没有住所的被告提起除身份关系以外的诉讼，可由位于我国领域内的合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地、代表机构住所地的法院管辖
扩大管辖	涉外民事纠纷与我国存在其他联系，可由我国法院管辖
协议管辖	涉外民事纠纷当事人书面协议选择我国法院管辖，可由我国法院管辖
默认管辖	当事人未提出管辖异议，并应诉答辩或者提出反诉，视为我国法院有管辖权
专属管辖	下列民事案件，由我国法院专属管辖： **公司纠纷**：因在我国领域内设立的法人或者其他组织的设立、解散、清算，以及该法人或者其他组织作出的决议的效力等纠纷提起的诉讼； **知识产权纠纷**：因与在我国领域内审查授予的知识产权的有效性有关的纠纷提起的诉讼 **中外合同纠纷**：因在我国领域内履行中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同发生纠纷提起的诉讼。
平行诉讼的管辖：**我国法院可以管**	当事人之间的同一纠纷，一方当事人向外国法院起诉，另一方当事人向我国法院起诉，或者一方当事人既向外国法院起诉，又向我国法院起诉，我国法院有管辖权的，可以受理。 规律：有向我国法院起诉的
外国管辖：我国法院可不管	当事人订立排他性管辖协议选择外国法院管辖**且不违反专属管辖**，不涉及我国主权、安全或者社会公共利益的，我国法院可以

	裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。
中止诉讼	我国法院受理案件后，当事人以外国法院已经先于我国法院受理为由，书面申请我国法院中止诉讼的，我国法院可以裁定中止诉讼，但下列情形的除外：
	当事人协议选择我国法院管辖，或者纠纷属于我国法院专属管辖。
	由我国法院审理明显更为方便。
中止后再恢复	外国法院未采取必要措施审理案件，或者未在合理期限内审结的，依当事人的书面申请，我国法院应当恢复诉讼。
已判决不受理	外国法院作出的发生法律效力的判决、裁定，已经被我国法院全部或者部分承认，当事人对已经获得承认的部分又向我国法院起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。

【知识点】必要共同诉讼与普通共同诉讼比较

	必要共同诉讼	普通共同诉讼
当事人人数	当事人一方或双方为 2 人以上	
诉讼标的	共同的（1 个）	同一种类（多个）
是否可分	不可分，**必须合并审理**	可分，**不一定合并审理**
裁判	必须同一裁判	应当分别裁判
诉讼人之间关系	共同诉讼人**必须一同起诉或者一同应诉**，彼此有连带关系，其中 1 人的行为经其他共同诉讼人承认，对其他共同诉讼人发生效力	普通的共同诉讼人之间没有共同的权利义务，其中 1 人的行为，对其他共同诉讼人不发生效力
管辖法院	只有一个诉讼，按规定法院管辖	几个诉讼必须属于同一法院管辖、适用同一种诉讼程序

【知识点】民事诉讼证明对象

须证明的对象	**无须证明**的事实
（1）当事人主张的民事实体权益所根据的事实。（如借钱的事实） （2）当事人主张的具有程序性质的法律事实。（如管辖地点正确与否） （3）外国法律和地方性法规、习惯。 （4）证据性事实	（1）**自然规律以及定理、定律** （2）**众所周知**的事实 （3）根据**法律规定推定**的事实 （4）根据**已知的事实和日常生活经验法则推定**出的另一事实 （5）已为人民法院**发生法律效力的裁判所确认**的事实 （6）已为仲裁机构**生效裁决所确认**的事实 （7）已为**有效公证文书所证明**的事实 （8）当事人在诉讼中**自认**的事实 第（2）项至第（4）项规定的事实，当事人有相反证据足以反驳的除外；第（5）项至第（7）项规定

	的事实，当事人有相反证据足以推翻的除外

【知识点】简易程序

（一）简易程序特点

项目	内容
方式	可以**口头**起诉
程序	可以**当即审理**，也可以**另定日期审理**
传唤	可以用简便方式随时传唤当事人、证人
组织	实行**独任制**
开庭	无须事前通知、公告，无须遵循普通程序规定的审理阶段
审限	应当在立案之日起 3 个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长 1 个月

（二）简易程序的适用范围与特殊规定

1.适用范围

（1）适用简易程序的案件：**基层**法院和它**派出的法庭**审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件。

（2）**不适用**简易程序的案件：①起诉时**被告下落不明**的；②发回**重审**的；③当事人一方**人数众多**的；④适用**审判监督程序**的；⑤涉及**国家利益、社会公共利益**的；⑥**第三人**起诉**请求改变或者撤销生效判决、裁定、调解书**的；⑦其他不宜适用简易程序的案件。

2.简易程序转为普通程序

（1）法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序。案件转为普通程序审理的，审理期限**自法院立案之日计算**。但是，**已经按照普通程序审理的案件，在开庭后不得转为简易程序审理。**

（2）在简易程序进行中，允许当事人对适用简易程序提出异议。当事人一方或者双方就适用简易程序提出异议后，法院应当进行审查。异议成立的，应当将案件转入普通程序审理，并将合议庭的组成人员及相关事项以书面形式通知双方当事人；异议不成立的，口头告知双方当事人，并将上述内容记入笔录。

3.其他特殊规定

（1）基层法院和它派出的法庭审理简单的民事案件，可以用**简便方式传唤当事人和证人、送达诉讼文书、审理案件**；

但应保障当事人陈述意见的权利。

（2）适用简易程序审理的民事案件，应当一次开庭审结，但法院认为确有必要再次开庭的除外。

（3）法院在制作裁判文书时对认定事实或者判决理由部分可以适当简化的情形：

①当事人达成调解协议并需要制作民事调解书的；

②一方当事人在诉讼过程中明确表示承认对方全部诉讼请求或者部分诉讼请求的；

③当事人对案件事实没有争议或者争议不大的；

④涉及个人隐私或者商业秘密的案件，当事人一方要求简化裁判文书中的相关内容，法院认为理由正当的；

⑤当事人双方一致同意简化裁判文书的。

第十七章　刑法

【知识点】追诉时效

（一）追诉时效的期限

法定最高刑 X	追诉时效	起算点
X＜5 年	5 年	（1）一般犯罪的追诉期限：从**犯罪之日**起算 （2）有连续或继续状态的犯罪：从**犯罪行为终了之日**起算
5 年≤X＜10 年	10 年	
X≥10 年	15 年	
无期徒刑、死刑	20 年	
	20 年后认为必须追诉，报请最高人民检察院核准	

（二）追诉期限的计算

1.不受追诉期限的限制

（1）在检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或在法院**受理案件以后，逃避侦查或审判**的；

（2）被害人在追诉期限内**提出控告**，法院、检察院、公安机关**应当立案而不予立案**的。

2.追诉时效中断：

犯罪分子在实施犯罪行为后，在**追诉时效期限内又犯罪**的，前罪的追诉时效就此中断，并**从后罪成立之日起重新计算**。

【知识点】犯罪主体

1.自然人犯罪主体

<table>
<tr><td>年龄＜12</td><td>不负刑事责任</td><td rowspan="3">不满 16 周岁不予刑事处罚的，责令其**父母或者其他监护人加以管教**；在必要的时候，依法进行专门矫治教育</td></tr>
<tr><td>12≤年龄＜14</td><td>犯**故意杀人、故意伤害罪**，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，**经最高检核准追诉的**，应当负刑事责任</td></tr>
<tr><td>14≤年龄＜16</td><td>只对犯**故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪**负刑事责任</td></tr>
<tr><td>年龄≥16</td><td colspan="2">应当负刑事责任</td></tr>
<tr><td>年龄＜18</td><td colspan="2">（1）应当**从轻或者减轻**处罚；（2）犯罪时不满 18 周岁的人**不适用死刑、不作为累犯**；（3）符合**缓刑条件**的，**应当予以缓刑**</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年龄≥75</td><td>故意犯罪</td><td>**可以**从轻或者减轻处罚</td></tr>
<tr><td>过失犯罪</td><td>**应当**从轻或者减轻处罚</td></tr>
<tr><td colspan="2">（1）符合缓刑条件的，应当予以缓刑
（2）审判时已满 75 周岁的人，**不适用于死刑，但以特别残忍手段**</td></tr>
</table>

	致人死亡除外
精神病人	在**不能辨认或不能控制自己行为的时候**造成危害结果，经法定程序鉴定确认，不负刑事责任
	尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或减轻处罚
	间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任
醉酒的人	醉酒的人犯罪，应当负刑事责任
聋＋哑	**可以从轻、减轻或者免除**处罚
盲人	

2.单位犯罪主体

主体	公司、企业、事业单位、机关、团体
主观方面	有为本单位谋取非法利益的故意，由单位集体或者其负责人作出犯罪决定，并通过直接责任人员加以实施
两罚制	**对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚**
不属单位犯罪	（1）**个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的** （2）公司、企业、事业单位设**立后，以实施犯罪为主要活动的** （3）个人盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的 （4）单位一般成员实施的犯罪 （5）与单位的经营管理活动没有任何关系的犯罪 （6）仅为单位个别或少数成员谋取非法利益的 【提示】《刑法》分则特别规定可以由单位实施的犯罪，才能认定为单位犯罪

【知识点】累犯、自首

（一）累犯（一般累犯和特殊累犯）

1.一般累犯的成立条件：

（1）前罪和后罪都“**必须是故意犯罪**”。

（2）前罪被判处的刑罚和后罪应当判处的刑罚都必须是“**有期徒刑以上的刑罚**”。

（3）后罪必须发生在前罪“**刑罚执行完毕或者赦免以后的 5 年之内**”。

【解释】①刑罚执行完毕，是指主刑执行完毕，附加刑是否执行完毕不影响累犯的成立。对于被假释的犯罪分子，规定的 5 年期限，从假释期满之日起计算。

②被判处有期徒刑宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期满后 5 年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，因前罪判处的有期徒刑并未执行，不具备《刑法》第 65 条规定的“刑罚执行完毕”的要件，故不应认定为累犯，而应当撤销缓刑，将旧罪与新罪一并处罚。

（4）累犯不适用于不满 18 周岁的人犯罪。

2.特别累犯成立条件：

（1）前罪和后罪必须是危害“**国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪**

的犯罪分子”。

（2）后罪必须发生在前罪“刑罚执行完毕或者赦免以后”。

（3）对前、后罪所判处的刑罚种类及其轻重没有要求。

【提示】根据规定，对累犯，“应当”从重处罚。

（二）自首

1.一般自首：犯罪以后“自动投案”，“如实供述”自己罪行的行为。

自动投案	时间	（1）犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关掌握 （2）虽被掌握，但犯罪嫌疑人尚未受到调查谈话、讯问或未被宣布采取调查措施或者强制措施
	视为自动投案	（1）向犯罪嫌疑人所在单位、城乡基层组织或其他有关负责人投案的； （2）犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的； （3）犯罪嫌疑人确已准备去投案，或在投案途中被公安机关捕获，经查实确属真实情况的； （4）犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的； （5）明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的； （6）因特定违法行为被采取行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为的； （7）交通肇事后保护现场、抢救伤员，并向公安机关报告的
	彻底性	犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首
如实供述	是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行	

2.以自首论

适用	被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯（在案）
供述	如实供述司法机关尚未掌握的罪刑，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪刑属不同罪刑（其他罪行）

3.量刑情节

一般自首	（1）对于自首的犯罪分子，“可以”从轻或者减轻处罚；犯罪较轻的，“可以”免除处罚 （2）共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实，“可以酌情”予以从轻处罚
以自首论	对被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同

	种罪行的，“可以酌情”从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，**“一般应当”从轻**处罚
坦白	犯罪嫌疑人虽不具有刑法规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，“可以”从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，**“可以”减轻**处罚

【知识点】缓刑、减刑与假释的适用对象

	缓刑	减刑	假释
适用对象	拘役或3年以下有期，可以宣告； 对其中不满**18周岁**的人、**怀孕的妇女**和**已满75周岁**的，**应当宣告缓刑**	管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑	有期徒刑或者无期徒刑
限制	①**累犯**，不适用缓刑 ②**犯罪集团的首要分子**，不适用缓刑	判处拘役或者3年以下有期徒刑、被宣告缓刑的，一般不适用减刑	①**累犯**，不得假释 ②因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪＋10年以上有期、无期徒刑的

【知识点】逃税罪

1.逃税罪的犯罪构成

（1）客体：国家税收征收管理制度和税收征管权。

（2）客观方面：表现为采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，不缴或者少缴税款行为。

项目	内容
纳税人欺骗、隐瞒手段的情形	a.伪造、变造、转移、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证或者其他涉税资料的 b.以签订“阴阳合同”等形式隐匿或者以他人名义分解收入、财产的 c.虚列支出、虚抵进项税额或者虚报专项附加扣除的 d.提供虚假材料，骗取税收优惠的 e.编造虚假计税依据的 f.为不缴、少缴税款而采取的其他欺骗、隐瞒手段
“不申报”的情形	a.依法在登记机关办理设立登记的纳税人，发生应税行为而不申报纳税的 b.依法不需要在登记机关办理设立登记或者未依法办理设立登记的纳税人，发生应税行为，经税务机关依法通知其申报而不申报纳税的 c.其他明知应当依法申报纳税而不申报纳税的
应予立案追诉的情形	a.纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在**10万元以上并且占各税种应纳税总额10%**以上，经税务机关依法下

	达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的 b.纳税人 5 年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予 2 次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在 10 万元以上并且占各税种应纳税总额 10%以上的 c.扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在 10 万元以上的

（3）犯罪主体

逃税罪的主体为特殊主体，既可以是个人，也可以是单位；包括纳税人和扣缴义务人。

【提示】不负有纳税义务和扣缴义务的单位和个人，不能独立构成本罪主体，但可成为本罪的共犯。

（4）主观方面：**直接故意**。

2.逃税罪的处罚

（1）对多次实施逃税行为，未经处理的，按照**“累计数额”**计算（连续犯）。

【提示】“未经处理”，包括未经行政处理和刑事处理。

（2）逃税行为跨越若干个纳税年度，只要其中一个纳税年度的逃税数额及百分比达到规定的标准（10 万元以上、10%以上），即构成逃税罪。各纳税年度的逃税数额应当累计计算，逃税额占应纳税额百分比应当按照各逃税年度百分比的最高值确定。

【知识点】骗取出口退税罪

主体	1. 既可以是纳税人，也可以是非纳税人（**一般主体**）； 2. 既可以是个人，也可以是单位（不限于是否有进出口经营权）。
客体	复杂客体＝国家出口退税管理制度＋公共财产所有权
主观方面	**直接故意**，且具有骗取国家出口退税款的目的
客观方面	利用国家出口退税政策，以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，**数额在 10 万元以上**的行为。
假报出口或者其他欺骗手段	①使用虚开、非法购买或者以其他非法手段取得的增值税专用发票或者其他可以用于出口退税的发票申报出口退税的； ②将未负税或者免税的出口业务申报为已税的出口业务的； ③冒用他人出口业务申报出口退税的； ④虽有出口，但虚构应退税出口业务的品名、数量、单价等要素，以虚增出口退税额申报出口退税的； ⑤伪造、签订虚假的销售合同，或者以伪造、变造等非法手段取得出口报关单、运输单据等出口业务相关单据、凭证，虚构出口事实申报出口退税的； ⑥在货物出口后，又转入境内或者将境外同种货物转入境内循环进出口并申报出口退税的； ⑦虚报出口产品的功能、用途等，将不享受退税政策的产品申报为退税产品的； ⑧以其他欺骗手段骗取出口退税款的。

【提示 1】骗超了才是本罪。

骗取所缴税款的，按**逃税罪**处罚；骗取税款**超过所缴纳的税款部分**，以**骗取出口退税罪**论处。

如：缴纳税款 10 万元，虚报出口骗取 15 万元，则对其中的 10 万部分按逃税罪处罚；5 万元的部分按照骗取出口退税罪论处。

【提示 2】实施骗取出口退税罪，**同时构成虚开增值税专用发票等其他犯罪的**，根据牵连犯从一重罪处断原则，**按处罚较重的罪名定罪处罚。**

【知识点】涉税职务犯罪与受贿罪

受贿＋	徇私舞弊不移交刑事案件罪	**数罪并罚**
	徇私舞弊不征少征税款罪	
	徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪	
	违法提供出口退税凭证罪	教材未写

【知识点】涉税职务犯罪的主体

徇私舞弊不征、少征税款罪	税务机关工作人员
徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪	税务机关工作人员
徇私舞弊不移交刑事案件罪	**行政执法**人员
违法提供出口退税凭证罪	海关、外汇管理等国家机关工作人员

第十八章　刑事诉讼法

【知识点】刑事诉讼中的专门机关

专门机关	具体内容
人民法院	代表国家**独立**行使审判权
人民检察院	检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督 人民检察院是国家的侦查机关之一，是**国家唯一的公诉机关**，是专门的诉讼监督机关
公安机关	（1）**大部分案件的侦查权** （2）强制措施的执行权。对犯罪嫌疑人、被告人采取的**取保候审、监视居住、拘留、逮捕**都由公安机关负责执行 （3）刑罚的执行权。公安机关担负着对判处拘役、剥夺政治权利刑罚的执行职责

【知识点】刑事诉讼回避

（一）回避范围	1.审判人员 各级法院院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员、助理审判员、人民陪审员。
	2.检察人员 检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员和助理检察员。
	3.侦查人员 参加侦查、起诉、审判活动，负责调查犯罪、收集证据、查明案件事实的公安司法人员。
（二）回避理由	1.**身份不当** 审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求其回避： ①是本案的当事人或者当事人的近亲属的； ②本人或者其近亲属和本案有利害关系的； ③担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的； ④与本案的辩护人、诉讼代理人有近亲属关系的； ⑤与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。 规律：影响公正就回避
	2.**涉嫌违法违规** 审判人员具有下列情形之一的，当事人及其法定代理人有权申请其回避： ①违反规定会见本案当事人、辩护人、诉讼代理人的； ②为本案当事人推荐、介绍辩护人、诉讼代理人，或者为律师、其他人员介绍办理本案的； ③索取、接受本案当事人及其委托的人的财物或者其他利益的；

	④接受本案当事人及其委托的人的宴请，或者参加由其支付费用的活动的； ⑤向本案当事人及其委托的人借用款物的； ⑥有其他不正当行为，可能影响公正审判的。 规律：影响公正就回避
	3.**跨越诉讼阶段** 参与过本案调查、侦查、审查起诉工作的监察、侦查、检察人员，调至法院工作的，不得担任本案的审判人员。 在一个审判程序中参与过本案审判工作的合议庭组成人员或者独任审判员，不得再参与本案其他程序的审判。
	4.**任职回避** 依照法律和有关规定应当实行任职回避的，不得担任案件的审判人员
（三）回避种类	1.自行回避：自己申请回避
	2.申请回避：没有自行回避时，**当事人、法定代理人、辩护人、诉讼代理人**有权向法院申请其回避
	3.指令回避：未自行回避、未申请回避，公安、司法机关等有关组织或行政负责人做出回避的决定

【知识点】辩护人的诉讼权利

项目	具体规定
侦查期间	（1）侦查期间**辩护律师**可以： ①为犯罪嫌疑人提供法律帮助； ②代理申诉、控告； ③申请变更强制措施； ④向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。 （2）危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当**经侦查机关许可**
会见通信权	（1）**辩护律师**可以同在押的或者被监视居住犯罪嫌疑人、被告人**会见和通信**。**其他辩护人经法院、检察院许可，**也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信 （2）**辩护律师**持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求**会见在押的犯罪嫌疑人、被告人**的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过 48 小时 （3）**自案件移送审查起诉之日起**，可以向犯罪嫌疑人、被告人**核实证据**。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听
阅卷权	（1）自人民检察院对**案件审查起诉之日**起，**辩护律师**可以**查阅、摘抄、复制**案卷材料，**其他辩护人经检察院、法院许可**，也可查阅、摘抄、复制案卷材料 （2）辩护律师可以申请查阅作为证据材料向法院移送的讯问录音录像，值班律师可以查阅案卷材料 （3）复制案卷材料可以采用复印、拍照、扫描、电子数据拷贝等方式 （4）查阅、摘抄、复制案卷材料，涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当保

	密；对不公开审理案件的信息、材料或者在办案过程中获悉的案件重要信息、证据材料，不得违反规定泄露、披露，不得用于办案以外的用途
调查取证权	（1）辩护律师**经证人或者其他有关单位和个人同意**，可以向他们收集、调取与本案有关的材料 （2）辩护律师申请向被害人及其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，法院认为确有必要的，应当签发准许调查书 （3）法院收集、调取证据材料时，辩护律师可以在场
质询权	辩护人认为在调查、侦查、审查起诉期间监察机关、公安机关、检察院收集的证明犯罪嫌疑人、被告人**无罪或者罪轻的证据材料未随案移送**，申请人民检察院、法院、公安机关调取的，应当以书面形式提出，并提供相关线索或者材料
申请回避	认为审判人员、检察人员、侦查人员具有法定回避情形，有权向司法机关申请，要求有关人员回避；对驳回申请回避的决定，**有权申请复议**
控告权	认为公安机关、人民检察院、人民法院及其工作人员阻碍其依法行使诉讼权利的，有权向同级或上一级检察院申诉或者控告
助理	律师担任辩护人、诉讼代理人，经法院准许，可以带**一名助理**参加庭审。律师助理参加庭审的，可以从事辅助工作，但不得发表辩护、代理意见

【知识点】认罪认罚从宽

含义	指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪，对指控的犯罪事实没有异议，同意检察机关的量刑意见并在辩护人或者值班律师在场的情况下签署具结书的案件，可以依法从宽处理。从宽分为**实体从宽和程序从简**两方面。	
适用	贯穿刑事诉讼全过程，**适用于所有**刑事**案件**的侦查、起诉、审判**各个阶段**，没有适用罪名和可能判处刑罚的限定。	
“认罪”	指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议	
“认罚”	侦查阶段	表示愿意接受处罚
	审查起诉阶段	接受检察院拟作出的起诉或不起诉决定，认可检察院的量刑建议，自愿签署认罪认罚具结书
	审判阶段	当庭确认自愿签署具结书，愿意接受刑罚处罚
	【注】**犯罪嫌疑人、被告人享有程序选择权**，不同意适用速裁程序、简易程序的，**不影响“认罚”的认定**	
从宽	对“从宽”的理解	（1）是**“可以”从宽**，不是“一律”从宽。 （2）对犯罪性质和危害后果特别严重、犯罪手段特别残忍、社会影响特别恶劣的，即使犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚，也不能从轻处罚。此外，避重就轻，不供述关键犯罪事实，属于“虚假认罪”，不适用从宽制度
	对“从宽”幅度的把握	对罪行较轻、人身危险性较小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些；对罪行较重、人身危险性较大的，以及累犯、再犯，从宽幅度应当从严把握

【知识点】取保候审

项目	具体规定	
决定机关	公安机关、检察院和法院（同监视居住）	
执行机关	公安机关、人民检察院和人民法院决定取保候审的，由公安机关执行。国家安全机关决定取保候审的，以及人民检察院和人民法院办理国家安全机关移送的刑事案件决定取保候审的，由国家安全机关执行	
适用情形	（1）可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的；（轻罪） （2）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（危险小） （3）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（人道主义） （4）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的（期满）	
保证	（1）法院、检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人提出保证人或者交纳保证金。对同一犯罪嫌疑人决定取保候审，不得同时使用保证人保证和保证金保证 （2）对符合取保候审条件，具有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，法院、检察院决定取保候审时，可以责令其提供 1 至 2 名保证人：①无力交纳保证金的；②未成年人或者已满 75 周岁的人；③其他不宜收取保证金的 （3）保证人条件：与本案无牵连；有能力履行；享有政治权利；人身自由未被限制；有固定的住处和收入	
执行	一般义务	（1）未经执行机关（公安机关）批准不得离开所居住的市、县 【提示】如果取保候审是由检察院、法院决定的，执行机关在批准时，应当征得决定机关同意 （2）住址、工作单位和联系方式发生变动，24 小时内向执行机关报告 （3）在传讯的时候及时到案 （4）不得以任何形式干扰证人作证 （5）不得毁灭、伪造证据或者串供
	选择义务	（1）不得进入特定的场所 （2）不得与特定的人员会见或者通信 （3）不得从事特定的活动 （4）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存
期限	最长不得超过 12 个月，不得中断对案件的侦查、审查起诉和审理 【提示】监视居住最长不得超过 6 个月	

【知识点】侦查期限

期限	对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过 2 个月	
延长	1 个月	案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级检察院批准延长 1 个月

	2 个月	下列案件在规定的期限届满不能侦查终结的，经省级检察院批准或者决定，可以延长 2 个月： ①交通十分不便的**边远地区**的重大复杂案件 ②**重大**的**犯罪集团**案件 ③**流窜**作案的**重大复杂**案件 ④犯罪**涉及面广**，**取证困难**的重大复杂案件
		对犯罪嫌疑人可能判处 10 年有期徒刑以上刑罚，延长期限仍不能侦查终结的，经省级检察院批准或者决定，可以再延长 2 个月
重新计算	侦查期间发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自发现之日起重新计算侦查羁押期限	

【知识点】简易程序与速裁程序的适用范围

	简易程序	速裁程序
适用范围	**基层**法院管辖，且：①案件事实清楚、证据充分的；②被告人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议的；③被告人对适用简易程序没有异议的。 对适用简易程序，被告人及其辩护人享有申请权。检察院提起公诉时也可以建议。	**基层**法院管辖，且：①可能判处 3 年有期徒刑以下刑罚；②案件事实清楚，证据确实、充分；③被告人认罪认罚并同意适用速裁程序。
不适用范围	①被告人是**盲、聋、哑**人； ②被告人是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的； ③案件有重大社会影响的； ④共同犯罪案件中部分被告人**不认罪或对适用简易程序有异议的**； ⑤辩护人作**无罪辩护**的； ⑥被告认罪，但经审查认为**可能不构成犯罪**的； ⑦其他不宜适用简易程序审理的。	①被告人是**盲、聋、哑**人； ②被告人是尚未完全丧失辨认或控制自己行为能力的精神病人； ③被告人是**未成年人**的； ④案件有重大社会影响的； ⑤共同犯罪案件中部分被告人对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议或者适用速裁程序**有异议的**； ⑥被告人与被害人或者其法定代理人没有就附带民事诉讼赔偿等事项达成调解或者和解协议的； ⑦辩护人作**无罪辩护**的； ⑧其他不宜适用速裁程序审理的。